

Droit des personnes

Introduction: le droit des personnes est une branche du droit civil qui comporte les dispositions tendant à assurer la détermination, l'identification et la protection des personnes. Le droit des personnes est un droit vivant, c'est un droit qui n'est pas figé il évolue, c'est un droit de masse. Les enjeux de la matière concernent un nombre considérable d'êtres humains, et les concerne dans tous les aspects de leurs vies (Naissance, vieillissement).

Plan

Section 1: La notion de personnes

Le terme de Personne dispose dans le langage courant d'un sens particulier. Dans le langage juridique le sens de personne est un peu plus précis.

Paragraphe 1 : Élément de définition de la personne au sens juridique :

La notion de « personne » est très utilisée par le droit et pourtant, curieusement, c'est un terme qui ne trouve pas une définition possible dans nos textes (Ex: **code civil**). Néanmoins, il est indispensable de savoir **quel est le sens juridique de la personne car, de cette définition découlera l'application des règles de droit relative à cette catégorie**. Et les règles de droit relative à cette catégorie de personnes on les retrouvent principalement dans le **livre I du CC** qui s'intitule « **les personnes** ». Le dictionnaire juridique de Gérard Cornu, définit la « **personne** » comme « **l'être qui jouit de la personnalité juridique, c'est-à-dire, de l'aptitude à être titulaire de droit et assujéti à des obligations.** » Donc **la personne au sens juridique c'est l'être qui va jouir de droit subjectif (droit de vote, de propriété, du respect à la vie privé, à la protection du corps humain).**

Les droits subjectifs s'opposent au droit objectif qui est l'ensemble des règles de droit qui régissent le rapport des individus au sein de la société (code de la route, relation de voisinage). Le Droit objectif est composé d'un certain nombre de droits subjectifs. **Les droits subjectifs sont les droits que les personnes peuvent directement invoquer, dont elles sont bénéficiaires, ceux sont des prérogatives (droit au respect).**

La personne au sens juridique c'est celle qui jouit de ces droits subjectifs ; elle dispose de la personnalité juridique. On comprend bien que, personne juridique et personne humaine ont deux définitions distinctes, sont deux choses différentes. La personnalité juridique n'est pas une qualité que l'Homme possède par nature, c'est-à-dire que c'est une création du Droit, c'est une qualité attribuée par le Droit aux personnes ; à la différence de la personne humaine, de l'être humain qui lui, n'a pas besoin du Droit pour exister. Personne juridique est donc différent de personne humaine. En Droit, au sens juridique, la personne est un sujet de Droit pour qui le Droit est construit et qui peut se prévaloir de prérogatives attribuées et sanctionnées par l'autorité publique. La personne juridique c'est la personne qui est apte à avoir un patrimoine, apte à conclure des contrats, apte à agir en justice... Alors que dans le sens courant, instinctivement, quand on pense à la « personne », on pense que cela renvoie à l'être humain. Au sens juridique, le Droit reconnaît aussi des personnes qui ne sont pas des êtres humains.

En effet, il existe **2 catégories de personnes, les personnes physiques (humain, individus fait de chair et d'os) et les personnes morales (groupements qui vont permettre de mettre en commun des biens, des connaissances, une activité, un savoir-faire etc..., ceux sont des entités abstraites non incarnées comme les sociétés, les associations, les syndicats etc.).** Ainsi tous ces groupements sont considérés comme des personnes car ils ont la personnalité juridique. C'est pourquoi **les personnes morales vont avoir un patrimoine propre, un patrimoine distinct de la personne physique, elles peuvent agir en justice, et elles sont titulaires de droits et d'obligations.**

On distingue les personnes morales en deux catégories : les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public. Les personnes morales de droit privé sont les entreprises, les sociétés... Pour les personnes morales de droit public ceux sont l'Etat, les collectivités territoriales...

On voit bien qu'au sens juridique, la « personne » englobe plus qu'au sens commun. La personne au sens juridique ne se confond pas avec la personne humaine.

Paragraphe 2 : La définition des personnes par opposition aux choses

En Droit on a une distinction majeure qu'on appelle la « *summa divisio* » une division/distinction fondamentale entre deux catégories : les personnes d'un côté et les choses de l'autre. Les personnes sont les sujets de Droit autour desquelles tout le système juridique du code civil s'organise. Le premier livre du code civil est consacré aux personnes physiques qui disposent de droits sur des choses. Les choses livre II Code Civil. Choses dont elles vont s'échanger la propriété entre elles de différentes façons. Les différentes manières dont on acquiert la propriété livre III Code Civil. Les personnes sont la catégorie principale et les choses sont la catégorie résiduelle. Tout ce qui ne relève pas de la définition juridique des personnes au sens du Droit, est au sens juridique considéré comme une chose. La catégorie des choses inclue tout ce qui n'est pas considéré comme une personne au sens juridique et donc elle est extrêmement hétérogène (ordinateur, embryons/cadavre, chien...). Tout ce qui n'est pas personne est une chose. C'est la division fondamentale. La catégorie des choses est une catégorie donc très hétérogène et il n'y a donc pas de traitement unitaire des choses et, les choses sont soumises à un régime juridique différent en fonction de sa nature. La frontière entre « personne » et « chose » peut être parfois interrogée et peu pertinente.

A) Les choses en lien avec la qualité d'être vivant

Il y a un certain nombre de « choses » au sens juridique qui bénéficient d'un statut protecteur par rapport à leur lien avec leur qualité d'être vivant.

- Premier exemple, ceux sont les embryons humains ; juridiquement, ils ne sont pas des personnes mais, bien qu'ils soient choses, les embryons bénéficient d'un statut protecteur en leur qualité d'être humain.
- Les enfants nés sans vie, c'est-à-dire un enfant qui est mort-né. Il est né sans vie donc n'a pas la personnalité juridique mais, il bénéficie d'une protection. Art 79-1 alinéa 2CC
- Le cadavre humain, après le décès, le corps humain n'est plus une personne au sens juridique, néanmoins, il possède une protection et n'est pas traité de façon ordinaire comme toutes les autres choses. L'article 16-1-1 « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
- Les animaux traditionnellement relèvent de la catégorie des choses mais, depuis la loi du 16 février 2015, l'article 515-14 du code civil précise désormais que : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cet article ajoute que « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Ils restent donc des choses mais ne sont pas ordinaires, ils ont un régime juridique spécifique. Exemple : arrêt du 9 décembre 2015 Cours de Cassation, 1ère Chambre civile : une personne achetée un chien de race en animal de compagnie et, il s'est trouvé que le chien avait des problèmes de vue qui occasionné pour le propriétaire des problèmes de soins onéreux. Il est alors allé voir l'éleveur qui lui a vendu et demande un dédommagement pour prendre en charge une partie des soins et l'éleveur lui a proposé un remplacement. En droit de consommation, cela est possible. La question qui s'est posée c'est : est-ce que pour un chien cela peut se réaliser ? Ne

voulant pas qu'on le lui remplace, elle est allée en justice et les juges ont considéré qu'en effet, « le chien en cause était un être vivant unique et irremplaçable et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître sans aucune vocation économique ». Le remplacement était donc inenvisageable et il fallait privilégier un dédommagement pour prendre un compte la qualité d'être vivant du chien.

Ces différentes catégories de choses ne sont pas titulaires de droits subjectifs, ne sont pas des personnes au sens juridique mais, en tant qu'êtres vivants ou ex-vivants, ils doivent être respectés, protégés par rapports aux choses qui sont classiques. Ce régime protecteur démontre que la frontière entre les personnes et les choses méritent parfois d'être relativisée et nuancée.

B) Les robots et les machines intelligente

Un robot est une machine capable d'exercer certaines choses programmées. Aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle est très important et, on constate dans tous les secteurs la présence de ces derniers. Cette intelligence se développe toujours plus et, plus elle se développe, plus les juristes se questionnent. Plus ces robots vont être perfectionnés et autonomes, plus ils vont se rapprocher des êtres humains, plus la question de leur statut, de leur responsabilité va se poser. Par exemple, à Hong Kong, une société a créé Sophia, un robot humanoïde depuis 2015 et qui est programmé à tout apprendre en s'habituant aux comportements des Hommes. En 2017, Sophia a même acquis la nationalité Saoudienne alors que par principe, la nationalité est donnée qu'à des personnes au sens juridique. Le parlement européen se questionne aussi et, en 2017 il a adopté une résolution avec des recommandations concernant des règles de droit civil sur la robotique. Elle propose à terme la création d'une personnalité juridique spécifique pour les robots. Beaucoup d'auteurs soulèvent le fait que cela peut paraître absurde mais, dans tous les cas, ce genre de textes nous questionnent sur le développement de l'intelligence artificielle et sur toutes les retombées juridiques. Le Droit bouge, il est mouvant en fonction de ces avancées, de l'opinion publique, il est influencé par de nombreux secteurs sociaux, économiques.

Section 2 : L'évolution du Droit civil des personnes

Pendant longtemps, la personne était appréhendée dans sa sphère sociale, publique et collective, c'est-à-dire que ce qui comptait était le rôle de l'individu dans la vie juridique, sociale et non pas dans sa vie personnelle, individuelle. C'était sur l'individu acteur dans la vie commune. Au fil de l'histoire, on est allé vers une individualisation de la personne qui s'est faite en 2 étapes :

- **Passage vers la liberté et l'égalité.** En effet, autrefois, dans l'antiquité, la notion de personne était divisée entre la personne libre et la personne non-libre (esclave). En droit romain, l'esclave appartenait à son maître, faisait partie de son patrimoine comme les autres biens, ce qui permettait de les vendre. Néanmoins, le droit les considérait comme des personnes juridiques mais non libre ; pas des choses. C'est seulement dans la **Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789** proclame dans son **article 1** : « **Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux.** »
- **La reconnaissance de la personne en tant qu'individu doté d'une âme et d'un corps.** En 1804 le code civil appréhendait encore l'individu comme une personne qui compose la société, il n'était pas appréhendé dans sa sphère privée. Le lien avec l'être humain s'est resserré progressivement, on a pris de plus en plus en compte la **corporéité de la personne** et aujourd'hui, le code civil s'attache à la protection et au respect de la personne physique, à la fois son intégrité morale, et son intégrité physique. D'où ce mouvement d'individualisation. S'agissant de l'intégrité morale, la jurisprudence a, au cours du XXe siècle, développé ce qu'on appelle les droits de la personnalité, qui sont des droits qui visent à protéger l'intégrité morale des personnes, donc leur vie privée, leur honneur, leur réputation etc. C'est particulièrement la **loi du 17 juillet 1970** qui est venu consacrer cette évolution jurisprudentielle en venant ajouter un **article 9 sur le droit de la vie privée**. S'agissant de l'intégrité physique, le mouvant a été un peu plus tardif car c'est à la fin du XXe, face aux progrès des techniques

médicales et scientifiques, que l'on a pris conscience à quel point certaines techniques pouvaient venir porter atteinte au corps humain et à l'espèce humaine. Quand on a pris conscience par exemple du clonage, des incidences que cela pouvait avoir sur le corps humain, le législateur a adopté les premières lois de bioéthiques le 29 juillet 1994 qui ont consacré un principe de protection de l'intégrité physique des personnes. Ces lois bioéthiques ont reconnu de nouveaux droits subjectifs au profit des personnes comme le «droit à la dignité et au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie», dans l'article 16 de la bioéthique, le droit à l'intégrité du corps humain dans l'article 16-3. Depuis l'introduction de ces principes, les lois bioéthiques ont fait l'objet de révisions régulières, par exemple le 6 août 2004 qui a ajouté le respect de l'intégrité de l'espèce humaine dans l'article 16-4, puis le 7 juillet 2011 et le 2 août 2021. Ces lois bioéthiques évoluent au fil du temps et il y a même l'obligation de les faire évoluer (inscrit dans la loi). Ces règles bioéthiques (Chapitre du titre Ier du livre Ier) permettent de délimiter les droits que chacun peut avoir ou non sur son propre corps et elles nous interrogent sur certaines techniques, sur la façon de réglementer juridiquement certaines questions. Les thématiques de la bioéthique sont par exemple la question d'euthanasie, le don d'organe, les expérimentations sur le corps humain...

Section 3 : Les sources du Droit des personnes.

La source principale du droit des personnes est évidemment le code civil mais il y en a d'autres. Quand on parle de source, ça veut dire

A) D'autres codes que le code civil:

- Le code des sociétés
- Le code de la santé publique (CSP) qui regroupe toutes les règles relatives au corps humain, à l'accès à la PMA, au don d'organe, ou encore les règles relatives à l'interruption de grossesses. Certains articles du code de la santé publique sont reproduits dans le code civil. Dans celui-ci à la suite de l'article 16-9, il y a un extrait du CSP pour permettre aux juristes d'avoir l'avis général puis simplifié
- Le code pénal est une source du droit des personnes car on y retrouve toutes les règles relatives aux atteintes qui peuvent être portées à l'intégrité des personnes, des règles d'état civil, les infractions relatives à la personnalité comme la violation de la vie privée ou encore, les dispositions relatives aux atteintes à la dignité de la personne comme les discriminations.

B) Dans des lois

Certaines lois importantes n'ont pas été codifiées, c'est-à-dire que leur contenu, n'a pas directement été intégré dans des articles de codes existants. Des lois viennent modifier des articles ou en ajouter aux codes mais certaines viennent juste préciser une règle, la poser et cela sans qu'elle soit dans l'article d'un code : pas codifiées. Par exemple, les lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas des lois codifiées mais on peut les mobiliser devant le juge et les invoquer. A la fin du code civil, il y a une table des lois non codifiées

C) Des textes à valeur constitutionnelle

Il y a plusieurs textes à valeur constitutionnelle qui font partie du bloc de constitutionnalité. Ces textes comportent des règles au droit des personnes. DDHC et préambule de la constitution de 1946 qui comportent des droits relatifs aux personnes et à la famille (droit de se marier). PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), principes essentiels auxquels on accorde une valeur constitutionnelle. Ex: liberté d'association, liberté de conscience.

Mais c'est surtout la jurisprudence du CConst qui s'avère très intéressante pour le droit des personnes et ce particulièrement depuis l'instauration dans notre droit de la Question Prioritaire de

Constitutionnalité (QPC). QPC est un mécanisme qui permet à l'occasion d'une action en justice de soulever la question de la conformité d'une loi à la constitution.

Dans ce mécanisme le plaideur/ justiciable va affirmer qu'une loi législative est contraire aux droits et libertés garantis par une norme constitutionnelle. Cela va aboutir à ce que le CConst effectue un contrôle de constitutionnalité de la disposition. Si la loi est reconnue inconstitutionnelle, elle est alors abroger. Le CConst veut abroger une loi il peut laisser un délai au législateur le temps pour lui de la remplacer et de la rendre conforme à la constitution.

Art 16-11 Alinéa 2 CC 2004 « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort », on ne peut pas faire de test ADN sur un cadavre après sa mort sauf si la personne y a consentie de son vivant.

Cette disposition a été mise dans le code civil après 2004 après une affaire célèbre dans l'opinion publique « affaire Yves Montant » après son décès une jeune femme prétendait être sa fille et elle avait intenté une action en justice pour établir un lien de filiation. Les héritiers légaux ont demandé que l'on fasse faire un test de paternité en prélevant et comparant l'ADN de leur père avec celle de cette femme. Le public s'est alors indigné dans la foulée, pour éviter une nouvelle demande le législateur est venu inscrire dans le code civil que l'on ne peut pas prélever d'ADN d'une personne décédée s'il n'as pas donné son accord de son vivant.

→ Art 16-11 alinéa 2 CC

Dans le cadre d'une affaire en 2011 quelqu'un a sollicité de savoir si cet article était conforme à la constitution, et plus précisément si cette disposition était conforme au droit et respect de la vie privée des personnes. En ne nous permettant pas de faire cette recherche après le décès d'un ascendant, on ne nous permet pas d'établir un lien de notre identité (lien de filiation).

Le conseil constitutionnel a statué le 30 sept 2011 numéro 2011-173QPC que cette disposition est conforme à la constitution. Si la réponse avait été différente alors notre législation aurait été modifiée. C'est en cela que le conseil constitutionnel est une source du droit des personnes. Elle permet l'évolution du droit des personnes

D) Des textes supranationaux

Ce sont des textes du droit international. Parmi les sources du droit supranational le texte de référence c'est la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales (CESDHLF). Cette convention a été signée en 1950 dans une enceinte « le conseil de l'Europe ». Deux enceintes au niveau européen: UE et le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est une enceinte différente de l'UE. Le Conseil de l'Europe est plus large que le niveau européen 49 états partis. L'Union européenne ce sont des vocations de libertés de circulations des pays européens. Le Conseil de l'Europe est une enceinte de protection des droits fondamentaux. La cour de justice de l'UE (CJUE) est l'organe de juridiction de l'UE. La Cour Européenne des droits de l'homme CEDH est la juridiction qui protège les droits fondamentaux qui appartiennent au Conseil de l'Europe, c'est donc l'organe de juridiction du conseil d'Europe.

CEDH a une importance particulière en droit des personnes car elle fixe pour chaque être humain un socle minimal de protection, de droit et libertés. Que les états signataires s'engagent à respecter. CEDH pose notamment au respect de la vie privée et familiale Art 8. Elle énonce aussi la liberté du mariage Art 12. Égalité entre les époux Art 5 du protocole additionnel n°1. Ces droits évoqués ont leur effectivité assurée grâce au contrôle qui peut être opéré par la cour européenne des droits de l'homme qui est la juridiction qui est chargée de contrôler la bonne application. La cour européenne a construit une jurisprudence riche et évolutive notamment sur la base de l'Article 8 qui concerne le droit au respect de la vie privée.

Cette jurisprudence est à l'origine de certaines réformes en droit interne (droit français).

Ex: question du changement de sexe à l'état civil?

Sur cette question le droit français opposé un refus. La France a été condamnée par la Cour Européenne des droits de l'homme pour cette disposition, ce qui a fait que la France a changé de disposition.

Plus récemment la France a changé de disposition sur la gestation pour autrui. La France a aussi été condamnée par la Cour Européenne pour le refus de transcription des actes d'état civil étranger qui concerne la gestation pour autrui. Suite à cette condamnation la France a changé.

La CEDH elle est d'application directe en droit interne ce qui signifie que toute personne peut à l'occasion d'un litige, invoquer devant le juge français les dispositions de la CEDH pour faire dire par le juge qu'une disposition y est contraire, afin que le juge en écarte l'application dans le litige en question. La Cour européenne quand elle condamne un état le condamne à une petite somme de compensation mais elle n'abroge pas la loi. Cependant tous les pays qui ont signé cette convention ont intérêt de changer leurs lois pour se mettre en conformité pour éviter une nouvelle condamnation. CESDH est donc une source du droit des personnes et elle l'est particulièrement à cause de la jurisprudence de la CEDH

Section 4 : Les fonctions du droit des personnes.

Le droit remplit un double rôle à l'égard des personnes. Dans sa première fonction c'est d'instituer les personnes c'est-à-dire qu'il sert à définir qui sont les personnes au sens juridiques, il sert aussi à lui donner sa place dans la société, à lui reconnaître une existence propre et individuelle. Son deuxième rôle est de protéger les personnes, que ce soit leurs intégrités morale ou physique, mais aussi de protéger particulièrement les personnes dites « vulnérables » (les mineurs, les handicapés mentaux...).

Thème 1 La personnalité juridique

La personnalité juridique est une notion abstraite, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et de ces d'obligation. Les personnes au sens juridiques ne peuvent pas être confondues avec les personnes physiques.

Chaque être humain qui né vivant est viable est doté de la personnalité juridique c'est-à-dire qu'il est apte à être sujet de droit et d'obligation quelque soit son âge, son sexe, son état de santé et quelque soit sa nationalité.

Section 1 : L'acquisition de la personnalité juridique

La personne juridique se superpose à la personne humaine donc, le début et la fin de la vie humaine marque les bornes temporelles de la personnalité juridique. Mais le début de la vie humaine pose question. Pour la science c'est à la fécondation. Pour le droit c'est à un autre moment.

Paragraphe 1 le moment de l'acquisition de la personnalité juridique: la naissance

La personnalité juridique s'acquiert à la naissance par principe de simultanéité. Mais la naissance doit être distinguée de la fécondation. La naissance d'un enfant se matérialise par l'accouchement de la mère. L'accouchement est un fait juridique auquel la loi attribue des conséquences juridiques parmi lequel l'acquisition de cette personnalité juridique.

Acte juridique: Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (conséquences juridiques). Il peut être conventionnel ou unilatéral et obéit, en tant que de raison, pour sa validité et ses effets, aux règles qui gouvernent les contrats. **Acte juridique le plus courant est le contrat. Le contrat sert à faire une manifestation de volonté. Vente d'un téléphone, le vendeur veut de l'argent, l'acquéreur veut la propriété. Acte bilatéral. Alors qu'un testament est un acte juridique unilatéral. Car une seule personne peut faire produire les effets de droits.** Manifestation de volonté destinées à créer des effets de droit.

Fait juridique: Agissements ou événement auquel la loi attache des effets de droit (conséquences juridiques), à l'opposé du fait matériel qui en est privé. Les faits juridiques sont tantôt dits involontaires ou naturels (naissances, décès...), tantôt volontaires ou humains (accidents, paiements, délits, quasi-contrat...). Ils sont tantôt illicites (délit, quasi-délit...), tantôt licites (quasi-contrat...). **Art 1100-2 CC**

« les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».

Quand on vole un objet on commet un fait juridique, mais on ne cherche pas les effets juridiques qui découlent du vol. Condamnation au tribunal. Acte volontaire. Alors que le décès d'une personne est un acte involontaire mais il va y avoir des effets juridiques qui découlent de ce décès. La loi affirme que la mort d'une personne ouvre sa succession.

Tous les autres faits qui entraînent des effets juridiques sans que ces effets n'aient été recherchés.

A) formalités liée à la naissance

Il faut savoir que toute nouvelle personne doit être connue de l'état pour avoir un état civil. Toute nouvelle naissance doit être déclarer à la mairie du lieu d'accouchement dans les 5 jours qui suivent l'accouchement Art 55 CC. Si la déclaration de naissance n'est pas faite dans les 5 jours, alors seul un jugement permettra à l'officier d'état civil d'inscrire dans les registres cette naissance. Cette déclaration de naissance conditionne l'obtention d'un état civil, c'est la raison pour laquelle c'est une obligation légale de déclarer une naissance. C'est une infraction pénale de ne pas déclarer une naissance. Art 433-18-1 du code pénal.

A partir de la déclaration de naissance l'officier d'état civil va établir un acte de naissance qui comporte un certains nombres de mentions qui sont obligatoires. Art 57 CC.

Toute personne doit avoir un état civil même si les parents ne sont pas connus.

B) Les conditions pour que la naissance entraîne l'acquisition de la personnalité juridique.

Toute personne acquiert de façon automatique la personnalité juridique mais à condition de naître vivant et viable. Un enfant mort-né n'accède pas à la personnalité juridique.

Un enfant né vivant quand à la naissance il respire. La viabilité c'est la capacité naturelle de vivre, c'est l'aptitude à la vie, l'enfant viable c'est celui qui est physiologiquement capable de survivre. Cette notion de viabilité a été précisée par une circulaire du 22 juillet 1993 qui se réfère aux critères posés par l'OMS, selon lequel les enfants pesant au moins 500 grammes ou qui sont nés après 22 semaines d'aménorrhée. Ils sont présumés viables indépendamment de tout autres critères. De façon plus large tout enfant qui né vivant est présumé viable même s'il meurt quelques heures plus tard.

Ex: un enfant qui meurt au bout d'une heure. Il a eu une heure de personnalité juridique il dispose donc d'un certificat de naissance et de décès.

L'enfant qui né vivant est viable devient juridiquement une personne, il acquiert un statut juridique, il a une identité, un nom, des droits patrimoniaux. A contrario l'enfant simplement conçu (l'enfant qui est dans le ventre de sa mère et l'enfant né sans vie) n'ont pas la qualité de personne.

C) Quel statut juridique pour l'enfant sans vie?

L'enfant né sans vie n'accède pas à la personnalité juridique, au sens du droit il n'est pas considéré comme une personne. Donc le droit français prévoit pour marquer une certaine reconnaissance prévoit un statut. Loi du 8 janv 1993 qui a créé l'acte d'enfant sans vie. Art 79-1 alinéa 2 CC. Pour obtenir cet acte sans vie il faut un certificat d'accouchement. Cet acte d'enfant sans vie va être inscrit sur les actes de décès. L'acte d'enfant sans vie a certains effets juridiques, permet de donner un ou plusieurs prénoms, depuis le 6 déc 2021 ils peuvent donner un nom. Cet acte d'enfant sans vie permet d'inscrire cet enfant sur le livret de famille. Il donne aussi des droits sociaux, accès à un congé maternité, paternité. L'acte d'enfant sans vie permet de récupérer le corps à l'hôpital de l'enfant pour procéder à des funérailles.

Paragraphe 2 L'atténuation du principe d'acquisition de la personnalité juridique à la naissance: des droits et une protection accordés avant la naissance.

Avant la naissance l'enfant ne se voit pas reconnaître de personnalité juridique sauf exception.

L'exception : l'adage (expression lapidaire issue de la tradition juridique, énonçant, sous une forme concise et frappante, une règle de droit, une sentence morale ou un fait d'expérience) **infans conceptus** (l'enfant conçu)

Toutefois avant la naissance des textes spécifiques protègent l'embryon.

A) l'absence de personnalité juridique avant la naissance mais une protection relative

Avant la naissance l'enfant n'est pas protégé comme une personne mais il bénéficie d'une protection sous la qualification « d'être humain ». Mais la protection pénale est très relative.

1) Une protection sous la qualification d'être humain

La question du statut juridique de l'enfant avant la naissance est une question qui a été extrêmement discutée en doctrine (ensemble des écrits des auteurs de droit). Cette question est toujours discutée par rapport aux développements des techniques de procréation médicale.

Deux termes différents:

-Embryon pour faire référence à l'être humain dans les 8 premières semaines de développement

-Fœtus après 8 semaines

Embryon et le fœtus sont traités en tant qu'être humain.

• Textes qui protègent l'embryon

Art 16 du CC il dispose que « la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Cet article résulte des trois lois bioéthiques de 1994. L'être humain, c'est l'enfant qui est simplement conçu, qui doit être respecté dès le commencement de sa vie. On déduit de cet Art 16 un principe général de protection de la vie humaine prénatale. On trouve dans le code de la santé publique de nombreuses règles qui protègent l'embryon. Ces règles rappellent notamment que la conception d'embryon par des techniques médicalement assistées est strictement encadrée. Elle n'est permise que dans le cadre d'assistance à la procréation dans le cadre d'un projet parental d'un couple ou d'une personne. Art L2141-3 CSP qui précise qu'un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une AMP (assistance médicale à la procréation). Il est interdit de concevoir des embryons pour faire de la recherche, de même qu'il est interdit de faire des embryons à des fins industrielles ou commerciales. Ces dispositions sont retrouvées dans le code civil après l'Art

311-20 CC. —> demander à la prof

• Les limites de la protection des embryons

Des atteintes peuvent être portées à l'embryon.

-La première atteinte est l'interruption volontaire de grossesse. Depuis la Loi Veil de 1975, une femme peut décider d'interrompre sa grossesse de façon discrète jusqu'à la 12^e semaine de grossesse. Loi du 2 mars 2022 qui a porté le délai de 12 à 14 semaines.

Au-delà de 14 semaines de grossesse une interruption volontaire de grossesse peut être possible à condition d'avoir un motif médical. Art L2213-1 CSP.

La Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais considéré que le droit au respect de la vie privée implique un droit à l'avortement. En 2010, dans l'arrêt du 16 déc 2010 Cour Européenne, elle a considéré que l'article 8 ne saurait s'interpréter comme consacrant le droit à l'avortement. Outre-atlantique la Cour Suprême Américaine est revenue le 24 juin 2022 sur la jurisprudence de l'arrêt Roe Vs Wade qui datait de 1973, qui protégeait de façon constitutionnelle le droit à l'avortement.

-La possibilité de « détruire » des embryons qui ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Art L2141-4 CSP. « Les embryons pour lesquels il n'y a plus de projet parental, il est possible de mettre fin à leurs conservations »

L'Art L2141-4 CSP précise que « les membres d'un couple dont les embryons sont conservé peuvent demander la fin de la conservation des embryons ». Le conseil constitutionnel à considérer dans une décision du 27 juillet 1994 que le principe de l'article 16 du CC pouvait valablement ne pas concerner l'embryon fécondé in vitro.

-L'utilisation des embryons à des fins de recherches scientifiques. permet de faire des recherches scientifiques sur des embryons surnuméraire. Qui permet au couple qui n'as plus de projet parental, de donner ses embryons pour qu'ils fassent l'objet de recherches scientifiques.

A l'origine les lois de bioéthiques de 1994 on interdit des recherches/ expérimentation sur les embryons. Première révision la loi 6 aout 2004 est venue ouvrir une brèche a ce principe. Tout en maintenant l'interdiction cette loi est venue permettre a titre exceptionnel de telle recherche. Loi du 16 juillet 2013 a finalement renverse le principe en autorisant le principe de recherche sur l'embryon. Art L2151-5 paragraphe 1 CSP qui permet que des recherches scientifiques soient produite sur des embryons surnuméraires ou que des cellules dérivées de ces embryons soient utilisées dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques à des conditions très strictes.

(Ces embryons peuvent faire l'objet d'expérimentation ou que des cellules peuvent être prélevées très tôt a des principes thérapeutiques.)

Les recherches sont très encadrés, elles doivent avoir une finalité médicale. Il faut démontrer la pertinence scientifique de la recherche, et il faut aussi démontrer que ces recherches ne peuvent être faite autrement qu'avec des embryons humains. Ces recherches ne peuvent être faites que sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale a la procréation, embryons pour lesquels il n'y a plus de projet parental. Le couple dont les embryons sont issu doivent donner leurs consentements à cette recherche.

Les embryons bénéficie par la convention OVIEDO, convention internationale sur les droits de l'homme et de la bio-médecine qui a été adopter dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1997. Cette convention précise qu'il est interdit la conception d'embryons humain pour faire de la recherche. Les lois de bioéthiques ont eu leur dernière révision, loi du 2 aout 2021 « une durée limite de 14 jours qui est fixe pour la culture in vitro pour les embryons humains qui font l'objet d'un protocole de recherche » (on peut faire une recherche sur l'embryon de la fécondation à j+14).

2) Les conséquences au plan pénal de l'absence de personnalité juridique avant la naissance

Le rejet d'incrimination d'homicide involontaire sur le fœtus. Au plan du droit pénal l'enfant à naître n'ayant pas la personnalité juridique. Le droit pénal ne reconnaît pas l'homicide involontaire sur le fœtus dès lors qu'il ne naît pas vivant et viable.

Cette solution à été affirmer par la Cours de cassation dans un arrêt rendue en assemble plénière le 29 juin 2020. La situation était la suivante:

Il s'agissait d'une femme enceinte de 6 mois qui a subit un accident de la circulation à cause d'un chauffeur de camion qui conduisait en état d'ivresse. Elle survit mais l'enfant ne survit pas. En droit pénal l'Art 221-6 CP réprime l'homicide involontaire qui est défini « le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence ou négligence ». Le débat juridique à été de savoir si le terme autrui peut conserver le fœtus.

La Cour de Cassation à décider que l'Art 221-6 n'est pas applicable au fœtus. La Cour de Cassation a écarté l'homicide involontaire sur un fœtus décédé in utero. Le fœtus n'as pas la personnalité juriste, il n'est pas titulaire de droits.

La Cour Européenne des droits de l'homme à considérée que l'état français sur cette situation ne portait par atteinte a l'Art 2 CEDH (convention européenne des droits de l'homme), article qui protège

le droit à la vie. Selon la Cour Européenne l'Art 2 est silencieux sur les bornes temporelles du droit à la vie. Selon la Cour chaque état dispose d'une marge d'appréciation pour répondre à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne ou non de l'Art 2 de la CEDH. **Arrêt du 8 juillet 2004 Vo contre France**. Il existe des infractions spécifiques en cas d'atteinte au fœtus comme par Ex: **Art 223-10 code pénal** qui vient sanctionner le fait d'interrompre la grossesse d'une femme enceinte contre son grès. « L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000€.

B) L'exception: l'adage infans conceptus

1) Règles

Cet adage est une fiction selon laquelle l'enfant simplement conçu va être considéré comme étant née chaque fois qu'il en va de son intérêt. C'est une règle qui remonte à l'ancien droit (droit applicable avant la révolution Française) dont on retrouve des traces dans 2 art du CC, qui sont les **Arts 725 et 906 CC**.

Art 725 « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » précise les qualités requises pour pouvoir succéder/ hériter.

Art 906 « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. » . précise que pour recevoir une donation (vivant du donateur) il suffit d'être conçu au moment de la donation, il ajoute que la donation n'aura d'effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Cette adage/ maxime a été reprise par la jurisprudence pour l'étendre/ appliquer à d'autres circonstances que les deux cités. Cet adage a également été érigé en principe général de droit par la **Cour de Cassation** dans **une décision de la 1ère chambre civile du 10 déc 1985**. Cette règle signifie que l'enfant simplement conçu peut bénéficier d'une personnalité juridique anticiper s'il en va de son intérêt et à condition qu'à terme il naisse vivant et viable. Si l'enfant né vivant et viable il peut bénéficier de droit pour la période précédant sa naissance.

2) Les conditions de l'adage conceptus

Pour que l'adage s'applique et que l'enfant bénéficie d'une personnalité juridique rétroactive à sa conception, trois conditions doivent être réunies:

- La première condition est l'intérêt de l'enfant. Pour que l'enfant simplement conçu soit considéré comme né et bénéficiant de la personnalité juridique de façon rétroactive. Il faut qu'il y trouve un intérêt
- L'existence d'un enfant conçu: il faut que l'enfant a été conçu au moment auquel on voudrait dans son intérêt qu'il est disposé de la personnalité juridique. La date de conception d'un enfant est difficile d'être déterminer avec certitude, l'**Art 311 CC** énonce une présomption (mode de raisonnement juridique en vertu duquel on induit de l'établissement d'un fait un autre fait qui n'est pas prouvé) selon laquelle l'enfant est présumé avoir été conçu pendant une période qui s'étant entre le 300ième jours et le 180ième jours avant la naissance. C'est une présomption simple la preuve contraire est recevable.

Présomption simple: lorsqu'elle est réfutable après la découverte de preuves du contraire

Présomption irréfragable: une conséquence ou déduction tirée à partir d'un fait connu, pour laquelle il n'est pas possible d'apporter la preuve contraire

- La naissance ultérieure d'un enfant vivant et viable. Il faut que l'enfant vienne au monde vivant et viable. Il va alors accéder à la personnalité juridique qui peut rétro agir au jour de sa conception.

Deuxième chambre civile Cour de Cassation 14 déc 2017 (n°16-26.687). Il s'agissait d'un individu décéder à l'occasion d'un accident du travail alors que sa femme est enceinte. Peu de temps après son décès l'enfant née vivant et viable. La mère va intenter une action en justice pour demander une réparation de son préjudice moral à elle, mais elle va aussi demander une réparation du préjudice moral de l'enfant. Si on fait jouer adage infans conceptus l'enfant vas pouvoir bénéficier de ses dommages et intérêts alors même qu'il n'était pas né au moment du fait de l'accident (fait générateur). Si les conditions sont réunies l'enfant a le droit à une indemnisation. La condition d'intérêt de l'enfant, elle est remplie, il y a intérêt. Deuxième conditions elle était enceinte, donc enfant conçu. Troisième conditions l'enfant est né vivant et viable.

En résumé en droit français la personnalité juridique s'acquiert à la naissance à condition que l'enfant naisse vivant et viable. Si l'enfant né vivant et viable, l'acquisition de la personnalité juridique peut s'il en va de son intérêt rétro-agir au jour de sa conception qui est présumer avoir eu lieu durant la période allant du 300ième au 180ième jour inclusivement la naissance. Si l'enfant ne naît pas vivant et viable la personnalité juridique est censé n'avoir jamais existé.

Section 2 : L'extinction de la personnalité juridique

Toute personne conserve sa personnalité juridique jusqu'à son décès. Pendant longtemps il y avait la mort civile, on retirait la personnalité juridique à ceux qui avaient des condamnations très graves. Cela n'est plus le cas depuis 1854. Il y a des hypothèses selon lesquelles la détermination du décès est délicate. D'autres part il y a des situations où le décès est incertain.

Paragraphe 1 : La mort

La personnalité juridique cesse en même temps que le décès de la personne puisque la personne juridique voit sa vie humaine prendre fin.

A) Formalités liées au décès

Le décès d'une personne a de nombreuses conséquences juridiques. Donc il faut savoir avec certitude le décès de la personne. Il y a des situations dans lesquels la constatation du décès est évidente. On découvre un corps qui a tous les caractères d'une personne décédée, un corps inanimé, un corps avec une rigidité cadavérique... Il y a des hypothèses dans lequel le constat du décès est plus délicat.

C'est le cas dans les arrêts cardiaques. Pendant longtemps on considérait l'arrêt du cœur comme le décès. Mais aujourd'hui on sait qu'un cœur arrêter depuis peu de temps peut repartir, on sait que certaines réanimations peuvent n'avoir aucunes conséquences sur la personne. Aujourd'hui le décès d'une personne est actée par le constat de la mort cérébrale. Seul le constat de mort cérébrale peut permettre d'actuer juridiquement le décès de la personne et donc d'autoriser le prélèvement d'organes.

Une fois le décès constaté il fait l'objet d'un certificat médical qui va permettre d'aller déclarer le décès à l'état civil dans les 24h. Cela donne lieu à un acte de décès de l'état civil. Cet acte de décès fait l'objet d'une publication. Le décès entraîne l'extinction de la personnalité juridique et avec le décès prennent fin toutes les situations juridiques qui découlaient de cette personnalité juridique (mariage, pacs, patrimoine).

B) Le statut et la protection du corps humain après le décès

Le cadavre ne bénéficie plus des droits de la personnalité juridique (droit à la vie privée, droit à l'image...). Le cadavre est juridiquement considéré comme une chose mais il bénéficie d'un statut protecteur. Art 16-1-1 CC précise «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Décision de justice 1ère Chambre Civile 16 sept 2010 (09-67.456) dans laquelle cette dernière a jugé que le fait d'exposer des cadavres à des fins commerciales méconnaît (est contraire) aux exigences du respect, dignité et défense dues au cadavres.

Tout outrage à la mémoire des morts et civilement et pénalement réprimer Art 225-17 CP sanctionne les infractions de violation/profanation des tombeaux et sépultures.

Les volontés du défunt au sujet de ses funérailles doivent être respectées. Art 433-21-1 CP. Toute personne qui méconnaît les volontés du défunt de façon consciente s'expose à une sanction pénale.

Le devoir de respect du cadavre n'empêche pas que ce cadavre soit « exploité » notamment pour opérer des prélèvements d'organes. Le principe en droit français est qu'il peut-être procéder au prélèvement des organes d'une personne décédée des lors qu'elle ne s'y est pas opposée de son vivant L1232-1 alinéa 3 CSP « Le prélèvement d'organe sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut-être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. ». Ça signifie que toute personne est présumer consentante aux prélèvement de ces organes réalisés dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Cette présomption peut-être renversée par la preuve apportée du refus de la personne matérialisée notamment par son inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet ou peut-être prouvé par écrit. Le prélèvement d'organes ne peut avoir lieu que si un médecin a constaté le décès c'est-à-dire la destruction encéphalique irréversible (mort cérébrale).

Paragraphe 2: les éléments assimilés au décès

Il existe des situations dans lesquelles une personne disparaît, ne donne plus de nouvelles sans pour autant que l'on retrouve son corps. Deux situations différentes: absence et la disparition.

A) L'absence

L'absence c'est l'état dans lequel se trouve un individu dont-on ne sait pas s'il est vivant ou mort. C'est par exemple celui qui part faire des courses et qui ne rentre jamais et ne donne plus de nouvelles. Cette situation est encadrée par la loi Art 112 CC « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. ». Pour être absent juridiquement il faut que la personne soit absente physiquement, il faut que l'on ne sache pas où elle est et il ne faut pas avoir un quelconque doute sur le fait qu'elle soit morte. Le code civil organise en deux étapes successives la prise en compte des affaires de l'absence.

- 1) C'est la présomption d'absence, d'abord la présomption d'absence est une présomption de vie, on présume que l'absent est vivant. On présume que l'absent va revenir. C'est le juge des tutelles qui va constater la présomption d'absence après avoir été saisi par toutes personnes intéressées ou par le ministère public. Le but de cette présomption d'absence est de désigner un représentant de l'absent qui aura pour mission de gérer son patrimoine, de le représenter... Jusqu'à ce que l'absent revienne. D'un point de vue extra-patrimonial le présumer absent est supposé être encore en vie et

donc son statut matrimonial ne change pas. Si le présumer absent reparaît Art 118 CC « Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence. ». Il reprend possession de ces biens et il va se manifester pour mettre fin aux mesures qui visaient à le représenter. Si le présumer absent ne revient pas, ne reparaît pas, ne se manifeste pas. On peut ouvrir la deuxième phase

- 2) Déclaration d'absence. Si l'absence se prolonge dans le temps alors on en vient à se dire que l'absence s'explique probablement par son décès et le tribunal va alors pouvoir prononcer un jugement de déclaration d'absence. Dont les conditions sont prévues à l'Art 122 et aux articles suivants du CC. La loi impose un délai qui varie selon les cas:
 - s'il y a eu constatation en justice de la présomption d'absence. Le tribunal peut rendre un jugement de déclaration d'absence lorsque 10 années se sont écoulées depuis le jugement qui avait constaté la présomption d'absence.
 - s'il n'y a pas eu de constatation judiciaire la déclaration d'absence sera possible au bout de 20 ans à compter de ces dernières.

La déclaration d'absence est une présomptions de décès elle est prononcée par le tribunal judiciaire et produit sans rétroactivité tous les effets juridiques du décès (dissolution mariage, ouverture du testament...). Si l'absent reparaît ou que son existence est prouvée après le jugement d'absence l'Art 129 CC précise que la personne pourra demander l'annulation de la déclaration d'absence. Au plan patrimonial il y aura retransmission des biens. Au point de vue extra-patrimonial (mariage ou pacs) qui avait été dissout du fait du jugement d'absence reste dissous.

B) Disparition

Il y a des hypothèses dans lesquelles la procédure d'absence est totalement inadaptée car le décès de la personne paraît certain ce sont les Art 88 à 92 qui vont s'appliquer. L'hypothèse de la disparition c'est celle d'une personne qui a vécu une situation périlleuse au terme de laquelle elle ne donne plus signe de vie (Ex: marin perdu en haute mer, alpiniste qui a disparu avec une avalanche, personne victime d'un crash aérien ...).

Dans ces situations une forte présomption de DC porte sur la personne disparue et ceux malgré l'absence de corps. Le droit français met en place une procédure de disparition qui permet de constater judiciairement le DC lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre en danger sa vie alors même que son corps n'a pas été retrouvé Art 88CC « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé... ». Ce jugement vaut acte de DC et donc va être publié sur les registres d'état civil. Les effets du jugement sont les mêmes que les effets du jugement de déclaration d'absence. Il n'y a pas de délai. Si le disparu reparaît, il peut demander l'annulation du jugement dans les mêmes conditions qu'en matière d'absence et les effets seront les mêmes.

Thème 2 : l'identité des personnes physiques

Sous thème 1: l'état des personnes

L'état des personnes, on peut le définir comme étant l'ensemble des éléments caractérisant la situation juridique d'une personne au plan individuel (date, lieu de naissance, sexe...) au plan familial (question de la filiation de la personne, filiation maternel/paternel) et au plan politique (qualité de français ou d'étranger/ nationalité). C'est l'ensemble de ces éléments qui sont de nature à permettre d'individualiser cette personne dans la société dans laquelle elle vit.

On peut définir l'état des personnes comme l'ensemble des caractéristiques de la personne qui détermine selon la loi certains effets de droit et définissent son statut juridique.

L'état des personnes est sous-entendu étant un statut qui comporte des éléments imprescriptibles et indisponibles. Cela signifie que ni l'écoulement du temps ni la volonté des individus ne peuvent permettre, en principe de modifier le contenu. Pourtant on constate que certains éléments peuvent subir des modifications de l'état.

Section 1: les caractères de l'état des personnes.

Paragraphe 1: le caractère indivisible de l'état de personne.

On dit que l'état est indivisible. C'est-à-dire qu'une personne ne peut avoir simultanément deux états différents. Et donc ne peut réclamer certains attributs de son état et en répugner d'autres.

Ex: on ne peut pas être marié et dans le même temps demander des aides pour les personnes divorcées.

Paragraphe 2 : l'imprescriptibilité de l'état.

L'imprescriptibilité de l'état signifie qu'en principe la prescription extinctive tout comme la prescription acquisitive ne touche pas l'état des personnes. Traditionnellement on considère que l'état est imprescriptible.

Prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit en raison de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. Le droit d'agir en justice fait l'objet d'une prescription extinctive.

Ex: Si on a un litige on peut agir dans les 5 ans qui suivent le litige pour demander réparation à la justice.

En principe on ne perd pas son état du seul fait de l'écoulement du temps même si on ne s'en est pas prévalu. Ex: Une personne mariée ne redevient pas célibataire (ne perd pas son statut conjugal) au seul motif que cette personne vivrait seule et séparée de l'autre personne depuis longtemps. Seul le divorce permet de perdre le statut de marié. Si j'ai un lien de filiation avec un parent, peu importe qu'il est disparu le lien de filiation reste d'actualité.

Quand il s'agit de réclamer un élément de son état (une action d'état), la prescription extinctive peut-être opposée à la personne. Ex: en matière de filiation, si je suis né et que j'ai aucun lien de filiation avec un paternel reconnu. Je peux faire une action qui vise à établir ce lien (c'est une action d'état). Il y a un délai de 10 ans après la majorité pour faire établir son lien de filiation. Art 321 CC.

La prescription acquisitive, c'est le fait d'acquérir un droit par l'effet du temps.

Ex: matière immobilière, il y a un principe de prescription acquisitive pendant 30 ans sur un bien, on peut réclamer le titre de propriétaire du bien si une personne ne s'y oppose.

Appliquée à l'état des personnes cela signifie que le principe d'imprescriptibilité, signifie qu'en principe on ne peut pas acquérir un état du seul fait de l'écoulement du temps.

Il y a des exemptions qui vont relativiser cette imprescriptibilité, notamment en matière de nom de familles. Car la jurisprudence a déjà admis qu'une personne est pu acquérir un nom de famille par le fait d'une possession extrêmement prolongée de ce nom.

Paragraphe 3 : l'indisponibilité de l'état.

Quand on parle d'indisponibilité d'un bien ou d'un objet ça renvoie au fait qu'on ne peut pas librement disposer de cet objet/bien, on ne peut pas l'aliéner, ni le détruire ni en décider librement.

L'indisponibilité de l'état des personnes signifie que l'état des personnes est hors d'atteinte des

volontés individuels. La seule volonté individuel ne peut permettre en principe de remettre en cause les éléments qui constituent l'état de la personne. Ex: je ne pourrait pas signer un contrat avec mon père biologique qui ne m'aurait pas reconnu dans lequel je renonce à ma filiation paternel.

Selon les éléments de l'état l'indisponibilité est plus ou moins importante. Le statut conjugal peut-être modifié par ma volonté individuel. Ce principe d'indisponibilité de l'état concerne surtout la filiation, le nom et le sexe.

Ce principe est tempérer sur des éléments qui ...

Le principe d'indisponibilité peut-être illustré à travers la GPA. Le principe d'indisponibilité implique qu'il est interdit de porter atteinte aux éléments de l'état qui visent à identifier et individualiser les personnes. L'interdiction en droit français de la GPA illustre ce principe d'indisponibilité de l'état, car c'est sur le fondement de l'indisponibilité de l'état (et du corps humain de la femme) qu'est interdite la GPA. La GPA est définie comme un procédé médical qui consiste à faire porter un enfant par une femme que l'on va appeler la mère porteuse qui par la suite l'abandonne à la naissance au profit d'un couple ou d'un parent que l'on nommera « parent d'intention ».

Section 2: l'identification des personnes.

La GPA est interdite en droit Français. Le principe d'interdiction a d'abord été affirmé par la jurisprudence par un arrêt rendu par la cour de Cassation du 31 mai 1991 au nom de l'ordre public et au nom de l'indisponibilité à la fois de l'état des personnes et du corps de la femme. A la suite de cette décision le législateur est venu insérer en 1994 l'Art 16-7 précise que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle. La GPA est contrainte aux principes d'indisponibilité du corps humain. C'est une forme de mise à disposition du corps de la femme au profit de quelqu'un d'autre et c'est contraire aussi au principe d'indisponibilité de l'état de personne parce que le procédé vise à désigner comme étant mère de l'enfant une mère qui n'en a pas accouché. Traditionnellement la filiation maternelle biologique en droit Français est fondée sur l'accouchement. La mère c'est la femme qui accouche au niveau de la filiation biologique. La mère est toujours certaine « *mater semper certa est* ». Dans le procédé de GPA consiste à dire que c'est une manipulation du lien de filiation. C'est dire que la mère c'est celle qui est la mère d'intention.

Les vraies difficultés aujourd'hui autour de la GPA concernent les français qui vont dans d'autres pays pour effectuer cette acte. Que doit faire l'état français pour les couples qui ont recours à la GPA et qui après reviennent en France ?

1) L'interdiction de la GPA en droit Français n'empêche pas de transcrire le lien de filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger

La problématique en droit français a été de savoir si en présence de parents français qui se déplacent à l'étranger pour faire appel à une mère porteuse et qui reviennent en France avec soit un jugement étranger soit un acte civil étranger qui les désigne comme parent.

C'est d'autant plus complexe de trancher cette question car bien souvent un des deux membres du couple et biologiquement le parent de l'enfant. On s'est trouvé confronté à des actes étrangers qui désignent comme parent biologiques des parents d'intentions. Jusqu'en 2014 la Cour de Cassation refusait au nom de l'indisponibilité de l'état aux personnes de transcrire sur les registres français d'état civil, les actes d'état civil étranger quand les circonstances pouvaient laisser penser que l'enfant était issu d'une maternité de substitution.

Transcription: une personne française existe sur l'état civil français. Tous les actes d'état civil étrangers (venant de parent français) doivent être transformés en état civil français.

Ex: 1^{ère} chambre civile Cour de Cassation 6 avr 2011 n°10-19.053.

La France a été condamnée par la CEDH dans l'arrêt du 26 juin 2014 arrêt *Menneson contre France*. La CEDH a considéré que la position de droit français portait atteinte au droit à l'identité des enfants qui est une composante du droit au respect de la vie privée et familiale qui est protégée par l'Art 8 de la CEDH. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation.

Dans cette décision la cour a concentré son analyse sur la filiation paternelle car elle a considéré qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant à le priver d'un lien juridique dont la réalité biologique est avérée.

Depuis cette condamnation la position de la cour de Cassation a évolué, elle a d'abord autorisé la transcription de l'acte étranger pour la filiation paternelle quand l'acte étranger correspondait à la réalité, c'est-à-dire quand l'acte étranger donnait comme père biologique le père d'intention et comme mère biologique la mère porteuse.

Arrêt d'assemblée plénière 3 juillet 2015 n°15-50.002. Cette position était conforme au principe d'indisponibilité des personnes puisque dans ces hypothèses les documents étrangers ne désignaient pas comme étant la mère le deuxième parent du couple d'intention.

Pour le second parent d'intention qui pouvait être un homme (couple de même sexe) soit d'une femme (couple hétérosexuel) la cour de Cassation permettait d'établir le lien de filiation de l'enfant par le biais de l'adoption. Arrêt du 5 juillet 2017 n°16-16.455. Une fois la France condamnée par la CE les parents ont demandé le réexamen suite à cette condamnation.

Loi J21 en 2016 qui donne le droit de réexaminer une affaire quand la CE nous donne raison.

Ils refusaient que leurs filiations soient établies différemment pour le père et pour la mère. L'assemblée plénière de la Cour de Cassation, cette dernière a demandé avis à la Cour Européenne. La Cour de Cassation a tranché le 4 Oct 2019 n°10-19.053 dans lequel la Cour de Cassation est allée plus loin que ce qu'avait énoncé la cour européenne puisque la Cour est venue autoriser une transcription intégrale des actes étrangers aussi bien pour la filiation paternelle que la filiation maternelle.

Cette décision est néanmoins circonstancielle, la Cour prend des précautions. Elle considère que dans ce cas de figure, spécialement pour la situation de ces époux, leur imposer l'adoption porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant.

Sauf que 2 mois plus tard en 2019 la première chambre civile de la cour de Cassation vient réaffirmer un principe de transcription intégrale des actes civils étrangers même en cas de suspicion d'un GPA.

Cette jurisprudence a incité le législateur à réagir, ce dernier a voulu introduire un article pour empêcher les transcriptions intégrales dans les hypothèses de GPA. Cela n'a pas abouti, cela a abouti au sein de la loi bioéthique du 2 Aout 2021 une modification de l'art 47 CC qui est relatif en principe à la force probante des actes d'états civils étrangers. Désormais l'Art 47 CC dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en principe foi sauf à ce que d'autres actes ou d'autres pièces qui démontrent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Loi bioéthique 2021 est venue apporter que « celle-ci (cette réalité) est appréciée au regard de la loi française. ». Pour cette dernière citation nous ne savons pas comment l'interpréter.

2) l'interdiction de la GPA en droit français empêche toute action judiciaire visant à lui donner un effet lorsqu'elle a eu lieu sur le territoire Français.

En revanche la position du droit français est très claire concernant les procédés de GPA qui pourraient se dérouler sur le territoire français. Sur le territoire français la GPA est prohibée, interdiction d'ordre public. Arrêt cour de cassation du 12 sep 2019 n°18-20-472. Dans cette affaire il s'agissait d'un couple d'homme qui avait conclu un contrat de gestation pour autrui avec une femme en France et l'un des deux individus était donneur. Il y a eu une insémination « artisanale » la grossesse se poursuit, puis pendant la grossesse la femme reconnaît l'enfant et elle indique au couple que l'enfant est décédé à la

naissance. Elle fait reconnaître l'enfant par le père d'un autre couple et remet l'enfant à un autre couple qui est en attente d'adoption. L'enfant grandit chez le deuxième couple, cependant le père biologique apprend ce qui s'est passé il faut donc une action en justice pour contester le lien de filiation du second père. Son action a été jugée irrecevable parce qu'elle repose sur un contrat qui est prohibée par la loi. Proverbe en droit français (*fraus omnia corrumpit*) qui dit que « la fraude corrompt tout ».

Section 2 : Les actes d'état civil

Paragraphe 1 : différents actes et leurs fonctions

L'état civil est constitué de règles d'ordre public. Toute personne dispose d'un état civil et ne s'aurait s'en dispenser. L'acte d'état civil est un acte authentique (chercher des / acte sous signature privée) dans lequel l'officier d'état civil qui est une autorité publique constate les événements qui influent sur l'état des personnes.

Plusieurs événements font l'objet de déclaration à l'état civil et donc font l'objet d'acte d'état civil. Ces événements sont : naissance, décès, mariage et la reconnaissance d'enfant. Ces sont les 4 actes d'états civil pur. Au-delà de ces 4 actes on trouve aussi transcription de toutes les modifications d'état d'une personne, qui ne résulte pas d'un acte pris par l'officier d'état civil. Par exemple les adoptions, le divorce, le pacs, la déclaration d'absence ou encore l'acquisition ou la perte de la nationalité française.

Ces événements sont le plus souvent constitués par jugement. Ces événements qui influent sur l'état d'une personne sont indiqués en marge de son acte de naissance par des mentions marginales.

Les actes d'états civils servent à attester l'existence juridique d'une personne. Mais ils servent surtout à prouver l'état d'une personne (son âge, son lien de filiation, le statut matrimonial...) ce sont des moyens de preuves de l'état de la personne concernée. Ce sont des éléments de publicité de l'état.

Paragraphe 2: le contentieux autour des actes d'état civil

Il peut arriver qu'un acte d'état civil comporte des erreurs ou des omissions/ inexactitudes, la rectification des actes d'état civil peuvent être administrative soit judiciaire.

A) les rectifications administratives

La rectification sera dite administrative quand l'erreur ou l'omission sur l'acte s'avère être purement matérielle (faute sur l'orthographe d'un prénom, erreur sur la profession sur le domicile ...). Ces rectifications peuvent être faites soit par le procureur soit par l'officier d'état civil qui détient l'acte.

1) La rectification par l'officier d'état civil détenteur de l'acte

C'est une compétence qui a été donnée de façon récente loi du 18 nov 2016. On retrouve cette possibilité à l'Art 99-1 CC qui permet donc à l'officier d'état civil de rectifier les erreurs les plus simples dont on retrouve une liste à l'Art 1047 du code de procédure civile. Il suffira de prouver à l'officier d'état civil cette erreur et ce dernier effectue directement la correction de cette erreur.

2) la rectification à l'initiative du ministère public

Le dernier alinéa de l'Art 99-1 du CC permet au procureur de faire procéder à la rectifications des erreurs purement matérielles des actes en donnant des instructions au dépositaire des registres. Le procureur est considéré comme l'administrateur du service d'état civil.

B) Rectifications judiciaires

Dans le cas où l'acte contiendrait des omissions ou des erreurs qui concerneraient un élément substantiel de l'acte, autre que sur des éléments matériels. L'Art 99 CC prévoit une procédure de rectification judiciaire pour laquelle c'est le président du tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer.

Ex: il y aura une rectification judiciaire de l'acte quand il faudra mettre l'acte d'état civil avec des faits nouveaux. C'est le cas quand l'inexactitude de l'acte s'est révélé postérieurement à la rédaction de l'acte. Par exemple quand une personne a été autorisée à changer de nom ou de sexe.

Sous thème 2 : Les éléments d'identification de la personne.

Section 1: Le nom

Def du nom: il s'agit du mot ou l'ensemble de mots désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms avec parfois l'adjonction d'un pseudonyme, d'un surnom, d'une particule ou d'un titre de noblesse.

Le nom des personnes comportent au minimum deux éléments obligatoires:

- nom de famille, qui traduit le rattachement juridique d'un individu à une famille
- Le ou les prénoms attribués au moment de la naissance

Sur le nom il faut savoir que historiquement les principes onomastique (relatifs aux noms) ont connu une certaine évolution. C'est-à-dire que les principes qui gouvernent la composition du nom ont évolué au cours des siècles. Au MA les personnes ne portaient qu'un seul nom qui était choisi par les parents. Et le plus souvent ce nom choisi était en lien avec la religion, puisque bien souvent on donnait à l'enfant le nom du saint sous la protection duquel on plaçait l'enfant au moment du baptême. Au fil du temps la coutume s'est développée d'ajouter à ce nom un surnom créé soit à partir d'une caractéristique physique, soit par rapport à un lieu, soit par rapport à un métier.

L'enfant se voit attribuer en plus de son nom un surnom et c'est ce surnom qui par la suite s'est transmis aux générations. C'est donc ce surnom qui constitue l'ancêtre des noms de famille actuels.

paragraphe 1: L'attribution du nom de famille

Aujourd'hui on utilise l'expression nom de famille, cette expression a été introduite par la loi du 4 mars 2002. Cette loi a substitué le nom de famille au nom patronymique.

Car le nom patronymique faisait référence au nom de famille du père. Le nom de famille est un élément qui relève à la fois de l'intérêt général, mais aussi de l'intérêt personnel de l'individu. Dans l'aspect intérêt général le nom de famille sert à identifier des individus, identifier des sujets de droit. C'est une institution de police civile qui relève de l'intérêt général.

C'est la raison pour laquelle l'état exerce un contrôle important sur les questions relatives au nom de famille des individus.

Le nom de famille est aussi un élément de l'identité des personnes qui relève de leurs sphères privées/individuelles. C'est la raison pour laquelle on constate aujourd'hui que sur de nombreux points le droit évolue pour prendre en compte les volontés individuelles dans l'attribution du nom de famille.

La question de l'attribution du nom de famille d'une personne se pose essentiellement au moment de sa naissance. Mais cette question peut aussi se poser lorsqu'une personne se marie.

A) l'attribution du nom à la naissance

Pendant longtemps la tradition voulait que l'enfant prenne le nom de son père, on parlait alors de nom patronymique. C'est la loi du 4 mars 2002 qui a rompu avec cette tradition. Elle a rompu avec le dévouement systématique du nom du père à l'enfant au moment de la naissance, pour permettre aux parents de choisir le nom de famille de leur enfant, qui peut donc être le nom du père/ le nom de la mère/ soit les deux.

Les règles relatives à la dévolution du nom de famille à l'enfant dépendent de sa filiation et plus précisément, dépendent du fait de savoir si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents. Ou si la filiation n'est pas établie de façon simultanée à l'égard des deux parents.

On peut considérer que le lien de filiation est établi simultanément à l'égard des deux parents notamment si l'enfant est né de parents mariés car la présomption de paternité va permettre de considérer le mari de la mère comme étant le père de l'enfant (pas besoin de faire un acte de reconnaissance). L'établissement sera également simultané de la filiation si l'enfant est né de parents non mariés mais dont le père a procédé à la reconnaissance de l'enfant au moment de la déclaration de naissance à l'officier d'état civil.

1) Si l'établissement du lien de filiation est simultané au moment de la naissance

Dans cette hypothèse l'Art 311-21 CC pose le principe selon lequel, les parents peuvent choisir ensemble le nom de famille de l'enfant. Ils ont la possibilité de choisir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix. En pratique ils doivent faire une déclaration conjointe de choix de nom par écrit qui est datée et signée par les deux parents. À défaut de fournir cette déclaration de nom de famille, l'enfant prend le nom de son père, s'il s'agit d'un couple hétérosexuel, soit dans un couple de femme, l'enfant prend les deux noms (dans l'ordre alphabétique).

On peut se poser la question en cas de désaccord?

Si les parents indiquent à l'officier d'état civil leur désaccord concernant l'état du nom, alors l'officier d'état civil va mentionner leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique. Le choix du nom de famille est très important, car ce dernier va ensuite être donné à tous les enfants communs du couple. Principe d'unité du nom dans la fratrie. Ce principe est retrouvé à l'Art 311-24 CC.

Deux parents qui ont chacun un double nom. On peut transmettre le nom de son choix dans la limite d'un nom par parent à cet enfant.

2) Si l'établissement du lien de filiation n'est pas simultané à l'égard des deux parents

Quand la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent au moment de la naissance, l'Art 311-23 prévoit que l'enfant prend le nom de ce parent. Ex: femme célibataire accouche et pour lequel aucun homme ne reconnaît l'enfant à la naissance.

Si ultérieurement le lien de filiation est établi à l'égard de l'autre parent, les parents peuvent alors pendant la minorité de l'enfant par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard de qui la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms dans l'ordre de leur choix, avec une précision « si l'enfant a plus de 13 ans son consentement personnel est nécessaire pour ce changement ».

Il y a des dispositions spécifiques pour les hypothèses dans lesquelles le lien de filiation est créé par adoption. S'il s'agit d'une adoption simple par un seul adoptant il est possible d'ajouter le nom de l'adoptant (consentement si l'enfant a plus de 13 ans), si il s'agit d'une adoption simple par deux adoptants mariés. Il y aura alors adjonction d'un des deux noms du couple. Si il s'agit d'une adoption plénière les règles sont identiques à celle de la filiation naturelle.

B) L'adjonction à titre d'usage du nom d'époux ou d'épouse

En cas de mariage chacun des époux conserve son nom de famille mais dispose alors du droit d'user du nom de son conjoint à titre d'usage. Le mariage donne le droit d'utiliser, de porter le nom de son époux ou de son épouse. Cette règle est inscrite à l'Art 225-1 CC qui dispose que chacun des époux peut porter à titre d'usage le nom de l'autre époux par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le mariage ne change pas le nom d'une personne, le mariage sert juste d'user du nom de l'autre mais ça ne modifie pas le nom de la personne. Pas de modification d'état civil. Le nom d'usage ne peut-être transmis car c'est un nom d'usage. Ce droit est une simple faculté. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser le nom du conjoint et il n'y a pas besoin d'autorisation pour utiliser son nom.

S'il y a une rupture du lien matrimonial.

Ce droit d'usage peut subsister dans certains cas, si le mariage est dissout en raison du décès d'un des époux, l'usage veut que le veuf ou la veuve puisse continuer à utiliser le nom.

Si le mariage prend fin en raison du divorce, en principe chacun des deux époux perd l'usage du nom de l'autre sauf si ce dernier l'autorise à le porter ou si le juge l'y autorise en présence d'un intérêt particulier pour soit ou pour les enfants. Art 264 CC.

Le juge aux affaires familiales s'il autorise l'utilisation du nom est pour l'intérêt. Le plus souvent pour une carrière qui à été faite avec ce nom. Ex: avocate qui fait sa carrière avec le nom de son époux, le jour de son divorce cela va être compliqué.

paragraphe 2: Les caractères du nom

Le nom de famille est immuable, c'est-à-dire qu'il ne peut en principe être modifier. Et cette immutabilité a pour conséquence que les noms sont aussi imprescriptible et indisponible.

A) Le principe d'immutabilité du nom de famille

Ce principe trouve son origine dans l'Art 1er de la loi du 6 fructidor de l'an II (23 août 1794), dispose «qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre». Ce principe impose à chacun d'user de son nom de famille dans la vie juridique à l'égard de l'état est c'est un principe qui est sanctionner au plan pénal par 2 infractions qui sont énoncés aux Arts 433-19 et 434-23 du CP.

Au point de vu civil le principe d'immutabilité du nom de famille implique en principe que le nom de famille ne peut-être modifié, mais il faut nuancer car on constate dans les règles relatives aux noms de familles que l'on accorde de plus en plus d'importance à la volonté individuel et plusieurs circonstances permettent de changer de nom de famille. Ces hypothèses sont des exemptions à l'immutabilité du noms.

Il y en a cinq:

- Le changement de nom résultant d'un changement de filiation. Une personne peut-être amener à changer de nom de famille au cours de sa vie si sa filiation vient à être modifiée. Ex: une personne qui fait l'objet d'une adoption peut prendre le nom de ses parents adoptifs. Une personne a qui avait été donner le nom de son père et suite à une action judiciaire ce lien de filiation paternel à été anéanti après une contestation, alors l'enfant perd le nom de son père et prend le nom de l'autre parent. Si la personne est majeur elle doit consentir au changement de son nom consécutif au changement de sa filiation. Art 61-3 alinéa 2 CC.
- Le changement en présence d'un intérêt légitime. Art 61 CC précise/ dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Cadre d'une procédure administrative. La demande de changement de nom doit-être formulée au près du garde des sceaux,

la demande doit exposer notamment les motifs pour lesquels la personne demande le changement de nom, et la demande doit indiquer le nom à porter, il doit y avoir un certain nombre de pièces, et si le changement est accordé le changement prend la forme d'un décret, publié au journal officiel. En cas de refus un recours est possible devant le juge administratif.

La formulation de l'Art 61 alinéa 1 est large, alors que l'alinéa 2 donne un exemple: hypothèse où une personne voudrait éviter l'extinction d'un nom porté par un de ses ascendants ou collatéraux jusqu'au 4ème degrés.

En pratique l'intérêt légitime qui permet le changement de nom est permis dans plusieurs hypothèses:

- Quand le nom porté par la personne est ridicule ou grossier. (Quand le nom suscite plus de sourires que de respect) B Tessier. C'était le motif principal de demande jusqu'en 1994.
- La volonté de changer de nom pour prendre le nom du parent qui n'a pas été transmis. En 2020 il y a 4293 demandes de changement de noms. Et quasiment une sur deux était fondée sur ce motif. 44% des décisions qui ont accepté le changement de nom ont été accordées sur ce motif. Du fait de ces nombreuses demandes sur ce motif une nouvelle procédure a été mise en place pour satisfaire à cette demande.
- Il y a une volonté de franciser son nom de famille.

Au titre des effets du changement de nom l'art 61-2 CC précise que le changement s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de 13 ans et au-delà de cet âge leurs consentements est nécessaire.

- Le changement permettant d'exercer le choix offert aux parents à la naissance. Prenant acte de ce qu'une grande partie des demandeurs de changement de noms sur le fondement de l'Art 61 CC l'étaient par des personnes qui sollicitaient le nom de leurs parents qui ne leur avait pas été transmis à la naissance. La loi du 2 mars 2022 a modifié les règles du CC pour prévoir une procédure simplifiée à cet effet. Désormais l'Art 61-3-1 du CC prévoit que toute personne majeure peut demander à l'officier d'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus au premier et dernier alinéa de l'Art 311-21 CC. Ce choix ne peut être fait en principe qu'une seule fois. L'objectif de cette disposition est de permettre à toute personne malheureuse de faire à sa majorité le choix qui avait été offert à ses parents le jour de la naissance.

Ex: Un enfant dont le père et la mère se nomment Dupont et Durand ont appelé leur fils Jean Dupont, à sa majorité Jean va pouvoir faire la demande pour s'appeler Durand et non plus Dupont. Ou Durand-Dupont. Ou Dupont-Durand. Cette demande avant 2022 n'était presque pas possible.

La demande doit être présentée à l'officier d'état civil, qui si il l'autorise consigne le changement dans le registre. Et ce n'est que dans le cas de difficulté que l'officier d'état civil peut saisir le procureur qui peut s'opposer à la demande.

Il y a un délai de réflexion. La demande de changement de nom ne prendra effet qu'après sa confirmation dans la même mairie au plus tôt un mois après son dépôt.

- L'acquisition d'un autre nom à l'étranger. La Loi J21 du 18 nov 2016 a ajouté des dispositions concernant l'acquisition d'un autre nom à l'étranger. Désormais l'Art 61-3-1 alinéa 2 CC dispose que toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre d'état civil d'un autre état peut demander en France son changement de nom, en vue de porter le nom acquis dans cet autre état.
- Le changement de nom suite à une naturalisation. Outre la procédure de l'Art 61 du CC, il est aussi possible pour toute personne qui acquiert la nationalité française de demander la francisation de son nom et éventuellement de son ou ses prénoms lorsque leurs consonances ou leurs caractères

étrangers gêne la personne. C'est une faculté. Cette francisation peut-être demander soit en même temps que la nationalisation française soit elle peut-être faire dans l'année qui suit l'obtention de la nationalité française. C'est prévu par la **Loi du 25 octobre 1972**.

B) L'imprescriptibilité du nom de famille

Le principe d'imputabilité du nom de famille entraîne comme conséquence, que le non usage d'un nom, même prolongé sur une longue durée n'est pas une cause d'extinction du droit pour son titulaire de le porter. En principe en temps qu'élément de l'état de la personne le nom de famille est imprescriptible. Ce principe a été énoncé par la **Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 1988 n°85-17.162**. Dans cette décision la Cour a énoncé que « si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ». Il s'agissait d'un individu qui portait comme nom de famille « Sainte Catherine », il invoquait que le nom de ses ancêtres s'était toujours écrit « de Sainte Catherine ». Et il faisait valoir que les services d'états civils avaient commis une erreur lorsqu'ils avaient établi l'acte de naissance de son arrière grand-père en 1840, sans cette particule. Il demandait la rectification de son acte de naissance. L'attendu de la Cour de cassation est que le fait d'avoir possédé suite à cette erreur pendant de nombreuses années le nom « Sainte Catherine » donne le droit au requérant d'avoir acquis ce nom. Mais ce n'est pas une obligation, et l'intéressé peut choisir de renoncer à cette acquisition pour réclamer le nom véritable de ses ancêtres. Qu'il n'a pas perdu en raison du non usage.

Après cette décision la jurisprudence a légèrement tempéré ce principe d'imprescriptibilité dans deux décisions:

- 25 mai 1992 n°90-13.613
- 6 avril 1994

La Cour de cassation est venue préciser que les juges du fond peuvent prendre en considération la durée respective et l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles se sont succédées. La reconstitution du nom d'origine est possible mais n'est pas accordée de droit par les juges qui devront apprécier la situation selon les critères évoqués (durée, l'ancienneté et les circonstances).

Ainsi s'il s'avère que le nom des ancêtres éventuellement altéré avec le temps n'a jamais été revendiqué les juges peuvent en déduire que les intéressés ont renoncé à ce patronyme. Les juges ont un pouvoir d'appréciation sur la demande.

On peut en conclure que le principe traditionnel d'imprescriptibilité du nom de famille est aujourd'hui nuancé puisque ces arrêts démontrent qu'en réalité un nom de famille peut s'acquérir ou se perdre du fait de l'écoulement du temps à certaines conditions.

C) L'indisponibilité du droit au nom.

Le droit au nom est hors du commerce juridique, il ne peut pas faire l'objet de convention. On ne peut pas autoriser à autrui l'usage de son nom au terme d'une convention. Le nom de famille échappe à la volonté individuelle. Mais ce principe d'indisponibilité peut-être nuancé, car depuis un célèbre arrêt du 12 mars 1985 Arrêt BORDAS, la jurisprudence a énoncé que « le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de son nom comme dénomination sociale ou non-commerciale. » Ce principe d'indisponibilité n'empêche pas de donner son nom à une société. Dans cette affaire Mr Bordas était fondateur d'une maison d'édition qu'il avait appelé par son patronyme et quand il a quitté la société, il a demandé qu'elle cesse de porter son nom. Les juges ont refusé de faire droit à sa demande.

considérant qu'il avait céder son nom de famille à la société. Ce nom était devenu un signe distinctif pour la société et que cette dernière pouvait garder ce nom et continuer à l'utiliser.

Section 2 : Le prénom

Le prénom est l'élément qui permet une différenciation individuel des membres de la famille qui portent le même nom. Toute personne doit avoir au moins un prénom.

paragraphe 1: Le choix du prénom

Qui choisit le prénom?

Le ou les prénoms d'une personne sont choisis par les titulaires de l'autorité parentale. S'il y a un désaccord il n'y a pas de texte pour réglementer cette disposition. On peut penser que c'est le juge des affaires familiales qui va être saisi.

Si les parents refusent de donner un prénom à l'enfant c'est l'officier d'état civil qui choisit trois prénoms, dont le dernier qui servira de nom de famille provisoire. (Instructions générales relatives à l'état civil). L'officier d'état civil va choisir les prénoms lorsqu'il s'agit d'un enfant trouvé ou quand aucun lien de filiation n'est établi. Une mère qui met naissance sous X peut donner des prénoms. Il n'y a pas de hiérarchie de prénoms inscrit sur l'acte de naissance. On peut tous les utiliser dans la vie courante.

Ce choix était-il libre?

Le choix du prénom est en principe libre, mais cela n'a pas toujours été le cas. Car pendant longtemps il était obligatoire de choisir un prénom figurant dans les différents calendriers ou un prénom connu. L'officier de l'état civil ne pouvait accepter que ces prénoms. Cette limite a été supprimée par la loi du 8 Janvier 1993 qui a posé le principe de libre choix du prénom. Le choix à cependant une limite qui est posée à l'Art 57 alinéa 4 CC « si les prénoms choisis ou un d'eux, seul ou associé aux autres semblent contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil en informe le procureur de la république, qui peut saisir le juge des affaires familiales. Le juge des affaires familiales va statuer pour savoir si le prénom choisi par les parents porte atteinte à l'intérêt de l'enfant ou non. Si c'est le cas il en ordonne la suppression sur les registres d'états civils et demande aux parents de choisir un autre prénom et à défaut il attribue lui-même un autre prénom. Art 57 alinéa 5. L'appréciation est souveraine par les juges en fonction de l'intérêt de l'enfant, et c'est pourquoi il y a des jurisprudences très étonnantes. Certains prénoms qui peuvent sembler étranges à certains égards ont pu être admis (Megane Renaud, Mickey, Zébulon). Les prénoms ont été accordés car c'est l'appréciation souveraine des juges qui choisit si le prénom peut porter préjudice à l'enfant.

Certaines fois la Cour refuse le prénom.

Arrêt de la cour d'appel de Rennes 25 janvier 2016, il s'agissait de parents qui ont appelé leur enfant Léo-Pard. Les juges ont considéré que c'était contraire à l'intérêt de l'enfant car cela faisait référence à un animal sauvage. L'enfant a donc été appelé Léo.

Cour de cassation du 1 février 2012, c'est le prénom Titeuf qui a été donné à l'enfant, les juges ont demandé de retirer ce prénom.

Cour d'appel de Montpellier en 2006, un enfant qui a été appelé « patriste, joyeux, soleil ». Ils ont accepté le prénom soleil. Et ont refusé les autres.

paragraphe 2 : la modification du prénom

Le prénom est en principe immuable, le changement du prénom n'est admis que de façon exceptionnelle, principalement dans 3 cas de figure

A) changement en présence d'un intérêt légitime

La procédure pour changer de prénom à été change par la loi du 18 novembre 2016. Jusqu'ici il fallait faire une demande devant le GAF, et il fallait démontrer un intérêt légitime. Les intérêts invoqués étaient divers (familiaux, grossiers, ridicules, l'usage prolongé d'un autre prénom peut constituer un intérêt légitime). Depuis la loi J21, la demande de changement de prénom est adressé à l'officier d'état civil a Art 60 CC, cet Art n'affirme plus directement qu'il faut démontrer un intérêt légitime. Mais le contrôle est tout de fois maintenu puisqu'il est précisé que si l'officier d'état civil juge que la demande de changement de prénom ne revêt par d'intérêt légitime, il saisit le procureur de la Rep qui va pouvoir former une opposition au changement de prénom. Dans cet hypothèse, s'il y a eu une opposition du procureur de la Rep le demandeur devra saisir le GAF pour qu'il statue.

B) les deux autres motifs de changement de prénom (francisation du prénom ou l'adoption de l'enfant).

Quand un enfant est adopté le tribunal peut sur demande de l'adoptant modifier le ou les prénoms de l'enfant. Art 361 et 357. Lorsqu'une personne acquiert la nationalité française elle peut demander la francisation de son prénom sur le même fondement que la francisation du nom.

Section 3 : le sexe

Le sexe est un élément de l'état des personnes, c'est un élément qui figure dans l'acte de naissance de chacun. Art 57.

Paragraphe 1 : le sexe dans sa dimension social

Pendant longtemps le droit civil faisait déduire des conséquences juridiques en fonction du sexe. Aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, d'abord sur le principe de l'égalité des sexes, on constate que ces distinctions n'existent quasiment plus.

Ex: jusqu'en 2013 il était impossible de se marier avec une personne du même sexe.

Ex: jusqu'à 2021 la PMA n'était offerte qu'aux couples de sexe différents. Depuis le 2 août 2021 elle est possible également aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Le principe d'égalité des sexes à une valeur constitutionnelle, il figure au troisième alinéa du préambule de la constitution de 1946 « la loi garanti a la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'hommes. » au plan politique ça signifie que les hommes et les femmes disposent des mêmes droits (votes, éligibilités...). Dans la sphère familiale ça se traduit par un principe d'égalité entre époux qui est venu remplacer le principe de la puissance maritale. Dans les rapports avec les enfants aussi. L'égalité des sexe à permis de transformer la puissance paternel en un principe d'autorité parental.

L'identité sexuel est pris en compte à certains égards, en revanche la sexualité est ignorée par le droit, car en principe le droit est indifférent à l'orientation sexuel des personnes. Mais il faut nuancer car le droit intervient toutefois pour sanctionner les discriminations qui pourraient être faites entre les personnes. La discrimination est considérée comme une atteinte à la dignité des personnes.

Paragraphe 2 : le sexe en temps qu'élément d'identification

L'identité sexuel d'une personne, traduit son appartenance à le genre féminin ou masculine. Du point de vu de l'état civil, toute personne est forcément soit un homme soit une femme. Nous allons traiter deux points:

- Les problématiques autour de la difficulté potentielle d'identifier le sexe d'un individu.
- Les problématiques juridiques autour de la dysphorie de genre, les difficultés qui peuvent exister pour les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur à été assigné à la naissance.

A) l'obligation d'inscrire un sexe à l'état civil

Du point de vu de l'état civil on est soit un homme soit une femme. Cette identité sexuel est d'abord déterminée sur la base de l'apparence, c'est au moment de la naissance que le médecin indique le sexe du bébé. Si cette identification est la plus courante il faut savoir que pour certains enfants la détermination du sexe est difficile. Il y a des enfants qui naissent de sexe indéterminé, il peut arriver qu'une personne présente les caractères des deux sexes, avec deux appareils génitaux, on utilise le terme personne intersexe. Dans ces hypothèses le droit civil ne permet pas de mentionner un sexe neutre. Cette question à été trancher par un arrêt de 2017 rendu par la 1ere chambre civile de cassation, à l'origine le (TGI =TJ aujourd'hui) avait autorisé de mettre un sexe neutre sur un état civil d'une personne qui était né ni homme ni femme, dans le sens ou cette personne avait les attributs des deux sexes. Les juges du fonds avaient admis que l'on puisse indiquer à l'état civil un sexe neutre. L'argumentation n'as pas été suivit dans les instances supérieures, et la cour de cassation à insister sur la nécessité de maintenir la binarité des sexes à l'état civil. La Cour à considéré que cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l'organisation social et juridique dont elle constitue un élément fondateur. La Cour ajoute « la reconnaissance par le juger d'un sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français, et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. ».

Jusqu'à 2021 il n'y avait qu'une circulaire qui apportait des éléments de réponse sur la marche à suivre pour l'identification à l'état civil de l'enfant intersexe. Circulaire du 28 octobre 2011, elle prévoyait une obligation d'inscrire le sexe qui paraissait le plus probable par rapport aux traitements possibles. En cas d'impossibilité totale de se prononcer à la naissance, la circulaire permettait de différer la mention de l'état du sexe à l'état civil pendant 1 à 2 ans pour déterminer définitivement le sexe de l'enfant à la suite de traitements. Il était conseillé aux parents de choisir un prénom mixte. Cette exigence juridique qui est liée à l'état civil à eu des conséquences très graves. Elle à conduit à des pratiques médicales très critiquables, c'est a dire des opérations chirurgicales à des enfants de moins de 24 mois pour assigner un sexe. Ces pratiques médicales portent atteintes à l'intégrité physique de ces enfants qui une fois devenu jeunes adultes ont pu exprimer toutes leurs souffrances (physiques et psychologiques), ce sont des opérations invasives. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont venus demander interdire ces pratiques. (Voir ces rapports).

Loi bioéthique du 2 aout 2021, qui est venue inscrire dans la loi des dispositions sur les personnes intersexes et un nouveau chapitre à été inséré dans le CSP qui est dédié aux enfants présentant une variation du développement génital. ce chapitre prévoit un protocole spécifique, avec une prise en charge dans des établissements hospitaliers désignés. Cette prise en charge à été designer dans l'art L2131-6 CSP, cet article prévoit une prise en charge pluridisciplinaire. Cette loi n'interdit pas les opérations chirurgicales sur des nouveaux nés, mais le dernier alinéa de l'article précise que le consentement de l'enfant doit être rechercher s'il est apte à la décision. Cela signifie que ces interventions médicales qui visent à assigner un sexe à l'individu resteront possible avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Normalement ces opérations devraient rester très exceptionnelles car elles entraînent souvent des mutilations, alors que normalement l'opération n'est possible que si elle relève d'un motif médical très sérieux. La loi bioéthique à aussi modifie l'Art 57 CC, pour prévoir comme le faisait la circulaire de 2011 la possibilité de ne pas inscrire de sexe à l'état civil pendant les 3 premiers mois de vie. Il faut avoir l'autorisation du procureur. Dans l'esprit de la loi bioéthique, ce délai de 3 mois n'as pas pour objectif de mettre en œuvre des traitements. Ce raccourcissement du délais s'explique probablement par le fait que la loi bioéthique à aussi modifié l'Art 99 CC pour permettre une rectification judiciaire de la mention du sexe sur l'acte de naissance au profit des personnes pour lesquelles il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.

Art L2131-6 CSP prévoit que les détails de la prise en charge des enfants intersexes doivent étres précisés par arrêtés pris après avis de la HAS. Le projet d'arrêté à été transmis à la HAS et cette

autorité à rendu son avis le 22 mars 2022, on comprend que se projet d'arrêté soutient les médecins qui réalisent des opérations sur les personnes intersexes le privilège de l'auto régulation, et se projet d'arrêté refuse aux associations de personnes concernés le droit de participer à la décision médicale. La HAS à contester fermement ce projet d'arrêté, car elle considère que le dispositif envisagé est contraire à l'esprit de la loi de bioéthique et contraire à tous les rapports qui on été rendu sur la question.

B) La possibilité de changer de sexe à l'état civil

Ces questions ne sont pas nouvelles, mais il peut arriver qu'une personne ressente son identité de genre différemment de son identification sexuel à l'état civil. Longue évolution sur la dysphorie de genre, autrefois on appelle cette situation le « syndrome de benjamin » ou « syndrome transsexuel ». Aujourd'hui on appelle ça la « dysphorie de genre », on se demande aujourd'hui s'il est possible pour ces personnes la modification du sexe à l'état civil et éventuellement un changement de prénoms. La réponse apporté par le droit à été évolutive.

1) Le droit français d'abord hostile au changement de sexe à l'état civil

Initialement la jurisprudence française au nom du principe d'indisponibilité de l'état des personnes refusait toute reconnaissance juridique à la suite de toute modification même chirurgicale, de l'apparence sexuel de la personne. Mais l'arrêt du 16 décembre 1975 n°73-10.615, cette affaire concerné un individu qui avait suivi un traitement hormonal et avait suivi une opération chirurgicale hors de France, ces traitements avaient fait une modification des attributs de son sexe, il à alors demandé un changement à l'état civil. La cour de cassation à répondu « que le principe de l'indisponibilité de l'état de personne, au respect duquel l'ordre public est intéressé, interdit de prendre en considération les transformations corporelles ainsi obtenues. »

Finalement la France à été condamnée par la CEDH par un arrêt du 25 mars 1992, Botella contre France. La CEDH à considéré que le refus de reconnaître le changement de sexe à l'état civil plaçait la requérante « dans une situation globale incompatible avec le respect du à sa vie privée ».

Suite à cette condamnation la jurisprudence à évoluée car la Cour de cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 11 décembre 1992, n°91-11.900 à admis qu'une personne transsexuel puisse voir son état civil modifié concernant la mention de son sexe, et quelle puisse également changer de prénom.

La Cour a admis dès 1992 le changement de sexe à l'état civil mais elle imposait des conditions strictes pour y faire droit.

Cependant la cour a demandé de démontrer :

- La réalité du syndrome transsexuel (la plupart du temps, il est exigée qu'il y est eu des expertises judiciaires).
- Un traitement médico-chirurgical subit dans un but thérapeutique (prouver une véritable réassignation sexuel, véritable conversion physique, ablation de certains organes génitaux). Ou des traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive et irréversible.
- Prouver une apparence physique proche de l'autre sexe.
- Démontrer un comportement social correspondant au sexe revendiqué, sexe psychologique (pour prouver un comportement social il faut démontrer avoir une possession d'état de l'autre sexe (comportement de l'autre sexe)).

A partir de 1992, on a eu des décisions des juges du fond très contradictoires. Il arrivait que le changement soit refusé parce que la personne avait refusé de se soumettre aux expertises.

La France à été de nouveau condamnée par la CEDH par un arrêt du 6 avril 2017 (arrêt Garçon et Nicot contre France), dans lequel la CEDH à considéré que la condition imposé par le droit français, qui

consistait à devoir prouver l'irréversibilité de la transformation de l'apparence était attentatoire au droit au respect de la vie privée. (Paragraphe 135). Le rejet de la demande au motif qu'il n'avait pas établi le caractère irréversible de la transformation de leur apparence, c'est à dire avoir démontré une opération stérilisante ou un traitement médical entraînant une forte probabilité de stérilité. S'analyse comme un manquement de l'état défendeur à son obligation de garantir le droit de ses derniers, au respect de leurs vies privées.

Le droit français a changé en 2017. Cependant la condamnation reste effective. Car cela permet aux personnes qui se sont vus refusés le changement d'état civil, de revenir devant la juridiction. Car une condamnation de la CEDH enlève l'autorité de la chose jugée.

2) La position actuelle du droit français.

Loi J21 du 18 novembre 2016, cette loi est venue inscrire dans notre code une disposition relative à la mention de changement de sexe à l'état civil. Elle est venue préciser la procédure à suivre l'Art 61-5 CC qui précise « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ». Désormais pour obtenir le changement de sexe il faut :

- Le demandeur se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué.
- Il faut qu'il démontre qu'il est connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel.
- Il peut aussi démontre qu'il a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Il doit démontre une réunion suffisante des faits. Il faut convaincre le juge de la possession d'état de l'autre sexe. Les éléments de faits énoncés par l'Art 61-5 rappellent les éléments de la possession d'état. Le changement de la mention du sexe à l'état civil, doit être accordé si le requérant démontre qu'il « possède l'état de l'autre sexe », qu'il se comporte comme étant de l'autre sexe.

(Def possession d'état: réunion des faits permettant d'établir la filiation d'une personne avec un parent dont elle se dit être le fils ou la fille.).

L'Art 61-6 al 3 CC « Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ». Aucun processus de conversion physique n'est maintenant imposé pour obtenir le changement de sexe à l'état civil.

La demande doit-être faite devant le tribunal judiciaire. Cela reste une compétence du juge de l'accorder ou non. Dans les débats parlementaires de l'adoption de la loi J21 il avait été envisagé de déjudiciariser le changement de sexe à l'état civil. Quand la modification est accordée par le juge l'acte de naissance du requérant est modifié mais si cette personne est marié et/ ou quelle a des enfants. La mention de son changement de sexe n'est pas transcrite sur l'acte de mariage ni sur l'acte de naissance de ses enfants. Car le droit veut garder un équilibre entre la vie privée du requérant et le respect à la vie privée des membres gravitants autour de cet personne.

3) Des questions récentes autour du changement d'état civil.

Trois questions d'actualité :

- Est-ce que les mineurs peuvent demander une modification de la mention de leur sexe à l'état civil ? L' Art 61-5 précise qu'il faut être majeur ou mineur émancipé. Il y a eut une décision récente rendue par la Cour d'appel de Chambéry du 25 janvier 2022 où il s'agissait d'une jeune femme de 17 ans, dont les parents avaient introduit une requête en modification de la mention de son sexe à l'état civil sur le

fondement des Art 61-5 et suivants. Le tribunal judiciaire de Chambéry au préalable avait jugé la requête irrecevable car la mineure n'était pas émancipée. Mais la Cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision après avoir opéré un contrôle de conventionnalité In Concreto. Les juges de la cour d'appel ont considérés que le refus de lui accorder ce changement alors que toutes les conditions étaient remplies porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par l'Art 8 de la CESDHLF.

- Question de l'accès à la PMA pour une personne transgenre, plus précisément pour un homme transgenre ?

En 2021 la loi de bioéthique a ouvert l'accès à la PMA au profit des couples de femmes et des femmes célibataires. À la suite de cette loi une association a saisi le CCont en invoquant que l'Art L2141-2 CSP serait contraire à la constitution et plus précisément au droit au respect de la vie privée et contraire au principe d'égalité. Cet Art L2141-2 limite l'accès à la PMA aux couples hétérosexuels, couples de femmes et aux femmes célibataires. Ce qui conduit à priver d'accès à la PMA les hommes transgenres (femme devenue homme) alors que certains d'entre eux peuvent être en capacité de porter la grossesse, car ayant conservé leurs attributs sexuels féminins. La femme devenue homme à l'état civil ne pourra pas accéder à un don de gamète, et un couple d'hommes dont l'un des membres du couple est transgenre ne pourra pas non plus accéder à la PMA alors même que l'homme transgenre pourrait porter l'enfant. Cette association reproche à cet Art L2141-2 une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacité gestationnelle selon la mention de leur sexe à l'état civil ce qui violerait le principe d'égalité. Cette association considérait aussi que cette disposition porterait atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale puisqu'elle contraindrait les hommes transgenres à renoncer à faire modifier la mention de leur sexe à l'état civil. Pour conserver la possibilité d'avoir accès à la PMA. Le CConst a statué dans une décision du 8 juillet 2022 et a considéré que cette disposition n'est pas contraire à la constitution car la différence de situation entre les hommes et les femmes au regard des règles de l'état civil pouvait justifier une différence de traitement quand aux conditions d'accès à la PMA. Le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes ayant des situations identiques.

- Concernant le lien de filiation à l'égard d'un parent transgenre ?

S'agissant du lien de filiation déjà établi entre la personne transgenre et ses enfants nées avant la modification du changement de sexe à l'état civil. Cette modification du sexe du parent n'a pas d'effet sur le lien de filiation déjà établi. Cependant l'assouplissement de la procédure pour obtenir une modification du sexe à l'état civil a engendré des nouvelles questions sur le droit de la filiation pour les enfants qui viendraient naître postérieurement à la filiation.

Ex: un homme marié qui obtient son changement de sexe à l'état civil, il devient femme. Et il n'a pas changé de sexe physiologiquement, il a un nouvel enfant avec son épouse, biologiquement en temps que père. L'enfant naît officiellement de deux femmes à l'état civil dont l'une est biologiquement père. Quel lien de filiation fallait-il consacrer ? Doit-on établir un lien maternelle selon son état civil ou doit-on la reconnaître comme le père biologique de l'enfant ? La requérante voulait être reconnue comme mère de l'enfant. D'abord la Cour d'appel de Montpellier, a dit que la mère est parent biologique. Un pourvoi est formé et la Cour de Cassation dans une décision du 16 septembre 2020 censure cette décision. La Cour de cassation rappelle que l'on ne peut pas inscrire deux filiations maternelles à l'état civil (autre qu'adoptive). La Cour considère que la mère transgenre doit utiliser les modes d'établissement de la filiation prévus pour le père. Doit faire une reconnaissance de paternité. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant une autre Cour d'appel pour trancher sur le fond. Entre temps, un an après cette décision la loi bioéthique 2021 intervient. Cette dernière vient permettre d'établir une double filiation maternelle dans le CC. La Cour d'appel de renvoi (Toulouse) le 9 février 2022 a pris acte des modifications de notre droit selon la loi de bioéthique et elle a autorisé la femme transgenre comme étant la mère de l'enfant dans l'acte de naissance de sa fille biologique.

Section 4 : Le domicile.

C'est le lieu d'identification d'une personne à travers un rattachement géographique ou territorial

Paragraphe 1 : détermination du domicile

A) Les principes relatifs au domicile

L'Art 102 CC qui définit le domicile, il dispose que le domicile de tout français quand à l'exercice de ses droits civil, est au lieu où il son principal établissement. Cet article nous illustre la fonction générale du domicile, c'est un élément d'individualisation de la personne physique. Le domicile a pour but de rattacher un individu pour l'exercice de ses droits à un point du territoire. La doctrine a déduit deux principes:

- Principe de nécessité : tout français doit avoir un domicile, c'est un élément de police qui est indispensable, car la loi attache de nombreuses conséquences à la détermination du domicile. Cette nécessité explique que les personnes qui n'ont pas de résidence fixe ou de domicile fixe. Peuvent élire domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet.
- Principe d'unicité du domicile : toute personne n'a qu'un domicile alors que l'on peut avoir plusieurs résidences.

B) Les modalités de détermination du domicile

Il y a des cas dans lesquels la loi détermine directement le domicile de certaines personnes. C'est le cas pour les mineurs selon Art 108-2 CC. Fixe le domicile des mineurs chez leurs parents. Art 108-3 fixe le domicile des majeurs sous tutelle chez leur tuteur. Ce sont des domiciles légaux de rattachement. En dehors de ces cas de rattachement légal du domicile, le domicile d'une personne est soumis à la règle du libre choix. Tout majeur est libre de choisir son domicile. Cette liberté de choix est un attribut au droit au respect de la vie privée.

Paragraphe 2: Les effets attachés à la détermination du domicile

Il y a de multiples intérêts liés à la localisation d'une personne par domicile. L'intérêt majeur est la fonction procédurale du domicile. Car le domicile d'une personne est attributif de compétences territoriales. Il permet pour certains litiges de déterminer quel est le juge compétent. Arts 42 al 1 et 43 CPC (code procédure civile) rattache sur le domicile du défendeur.

Le domicile permet aussi de déterminer le lieu de célébration ou d'accomplissement de certains actes juridiques. Art 165 CC. Le mariage est célébré par l'officier d'état civil de la commune dans laquelle un des époux a son domicile.

La loi donne aussi une importance particulière à la résidence. Qui reflète d'avantage une situation de fait que le domicile.

Thème 3 : la protection de l'intégrité morale des personnes.

La protection de l'intégrité morale des personnes, c'est la protection de toutes les qualités incorporels, immatériels de la personne qui la définissent dans sa relation aux autres. C'est la protection de son image, de sa vie privée, de sa voix. Tous ces éléments sont désincarnés mais sont protégés par des droits subjectifs qui protègent de façon globale l'intégrité morale des personnes.

La protection de l'intégrité morale des personnes est très souvent mise en balance avec d'autres droits et libertés fondamentales, comme par exemple la liberté d'expression, la liberté de la presse ou encore le droit à l'information. La protection de l'intégrité morale associe par la protection du principe de dignité. Le principe de dignité est particulièrement mobilisé dans ce thème de la protection morale.

Le principe de dignité, il innervent tous les droits que nous allons détailler dans ce thème et le suivant. Il est énoncé à l'Art 16 CC qui assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci. C'est un principe fondamental qui impose /qui commande que les intérêts de l'Homme doivent primer sur tous les autres intérêts (intérêts commerciaux, scientifiques...). Le principe de dignité signifie que l'on ne peut pas instrumentaliser les personnes, et ce principe fait obstacle à tout ce qui pourrait dégrader la personne humaine, prise à la fois dans son intégrité physique et dans son intégrité morale. Ce principe va venir lutter contre tout ce qui pourrait conduire à traiter la personne comme une chose.

Ex: On ne peut pas concevoir d'embryon humain autre que pour un projet parental.

Ce principe de dignité a une valeur constitutionnelle et avant d'être inscrit dans le CC (Art 16) il était déjà présent dans de nombreux textes internationaux (Déclaration universelle des droits de l'Homme, Convention d'Oviédo). C'est un principe que l'on considère comme matriciel, car tous les principes qui protègent la personne physique en découlent. Il est le fondement des principes qui protègent la personne physique. Toutes les règles qui visent à protéger les personnes des atteintes physiques et morales ont pour principe de préserver la dignité des personnes.

Arrêt du CE du 27 oct 1995 commune de Morsang sur Orge. Le conseil d'état est venu interdire des « spectacles » visant au lancer de nains.

Le préfet ou le maire a des pouvoirs pour interdire les spectacles. C'est un acte d'autorité publique.

Section 1: Les droits subjectifs protecteurs de l'intégrité morale des personnes.

Paragraphe 1 : Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image

Ce droit au respect de la vie privée est protégé par l'Art 9 CC mais aussi par l'Art 8 § 1 de la CEDH et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. C'est un droit fondamental, c'est un droit qui est constitutionnellement protégé depuis une décision du CConst du 23 juillet 1999 qui a intégré au bloc de constitutionnalité le droit au respect de la vie privée en le rattachant à l'Art 2 de la DDHC qui concerne le principe de liberté.

Il faut savoir que l'Art 9 du CC qui protège le respect de la vie privée a été introduit en droit français par la loi du 17 juillet 1970. Avant cette loi, notre droit civil ne comportait aucun texte protégeant la vie privée des individus de manière générale. Du fait de cette absence de texte avant 1970, c'est la jurisprudence qui a bâti/ édifié un régime protecteur de la vie privée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Sur le fondement de l'ancien Art 1382 qui est aujourd'hui l'Art 1240 CC « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ce texte imposait (1382) pour engager la responsabilité d'une personne que soit réunies trois conditions:

- Une faute
- Un préjudice
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le fait d'avoir consacré l'Art 9 dans le CC, permet désormais un allègement de la preuve à apporter puisque désormais la victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir réparation en prouvant seulement l'atteinte. Il n'est pas nécessaire de prouver un préjudice.

L'Art 9 du CC institue un droit dont la violation appelle automatiquement à la réparation

A) Les contours de la vie privée protégée et les titulaires de droit

Le droit au respect de la vie privée est une notion générale qui n'est pas définie par les textes. C'est la jurisprudence au grés des affaires qui a permis de définir les contours de la vie privée. De manière générale le droit au respect de la vie privée, c'est le droit de garder secret un certain nombre d'informations qui relèvent de la sphère privée de chacun.

Relève de la vie privée les événements qui se déroulent dans les lieux privés, mais en relève aussi les informations privées indépendamment du lieu où elles se déroulent.

1) La vie privée Stricto Sensu

Font évidemment partie de la vie privée les informations relatives à la vie personnelle. C'est le cas des informations à caractère privé et familial (vie sentimentale, vie conjugale, vie extra-conjugale, vie filiale, vie familiale, l'état de santé ou encore son domicile). Entre aussi dans la vie privée les opinions, les aspirations religieuses, la pratique d'un culte....

Ex: Arrêt de la 1^{ère} chambre civile 9 sept 2020 qui concernait un reportage télévisé dans « faites entrer l'accusé ». Une personne avait été victime d'abus sexuel. Cette affaire avait été jugée dans une audience à huis clos, l'accusé avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Dans ce reportage avait été donnée l'identité de la victime ainsi que les circonstances. La victime a saisi les juges sur le fondement de l'Art 9. L'atteinte a été reconnue, elle a pu obtenir réparation.

2) Le droit à l'image

Le droit à l'image a été dégagé par la jurisprudence. Il n'est pas expressément consacré par la loi. Mais c'est un droit qui permet à toute personne d'interdire au tiers la prise, la reproduction et la publication de son image de par quelque moyen que ce soit. Photographie vidéo dessins image de synthèse. C'est la reconnaissance d'un droit de contrôle sur la reproduction et la divulgation de son image.

L'Art 9 est sur la vie privée. Il y a des débats car certains auteurs car ils pensent que le droit de l'image ne doit pas être reconnu comme un droit patrimonial.

Ils mettent en avant que les droits de la personnalité sont des droits indisponibles, et qui sont en principe extra-patrimoniaux (impossible de la monnayer). Cela reviendrait à dire que les images ont une qualification de patrimonialité.

Le droit à l'image se base sur l'Art 9 du CC.

De manière générale c'est les droits de la personnalité qui ont perdu leurs côtés extra-patrimoniaux. Ex: interview qui contient des éléments de la vie privée de l'artiste. (Qui est monnayer)

Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image ne se confondent pas. Et le droit à l'image ne fait pas double emploi avec le respect de la vie privée. Bien souvent si on prend une photo de quelqu'un à son insu, c'est une atteinte au droit à l'image et non une atteinte au respect de la vie privée, si la photo est prise dans un cadre non privé.

Ex: si on va sur une course publique de vélo. Et on prend une photo d'un des coureurs et on utilise cette photo pour de la publicité, on est coupable de non respect du droit d'image mais pas au droit de respect de la vie privée.

A l'inverse si on prend une photo d'une star dans sa piscine personnelle, on est coupable d'atteinte au droit à l'image et au respect de la vie privée.

Arrêt 1^{ère} chambre civile de la Cour de cassation, 2 juin 2021, n°20-13.753.

3) Les autres composantes de la vie privée

Dans les autres composantes il y a :

- **Domicile**, qui est protégé comme un élément de la vie privée car il est considéré comme le siège de l'intimité des personnes. C'est au domicile que la vie privée se déroule. Les informations sur l'adresse d'une personne, sur son numéro de téléphone ne peuvent être rendues public sans son consentement. Le domicile fait l'objet d'une protection toute particulière. Car chacun peut refuser l'accès à son domicile. Le droit pénal sanctionne la violation de domicile comme une atteinte à la vie privée. Qui est sanctionner à l'Art 226-4 CP.

Il y a des exceptions (locataires, perquisitions ... ces exceptions sont très encadrées par la loi).

Le domicile qui est protégé par l'Art 226-4 CP s'entend plus largement que le domicile qui est défini par l'Art 102 CC.

Puisque sont protégés comme domicile, tous les lieux où la personne peut se dire chez elle, et donc quelle soit propriétaire, locataire, ou occupant à titre gratuit. Cela intègre les émergences temporaires (tentes, chambres hôtels...), elle protège aussi les lieux professionnels (bureaux, cabinet avocat, véhicule ...).

- **Correspondances**, les courriers, mails, e-mails, ou encore les conversations téléphoniques. Toutes les correspondances orales ou écrites sont protégées par l'Art 9 CC. D'ailleurs les articles 8 de la CEDH et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'UE font références aux correspondances. Art 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

S'agissant du droit à l'espèce de la vie privée la jurisprudence est difficilement lisible. Parce que les juges se livrent très souvent à une appréciation casuistique (situation au cas par cas) des situations/litiges qui sont soumis.

Dans les arrêts rendus, on constate parfois que la communication de fait qui relève de la vie privée n'engendre pas forcément une condamnation pour atteinte à la vie privée comme l'information est considérée comme anodine.

Arrêt 2ème chambre civile de cassation, 8 juillet 2004 n°02-17.458. Un article avait été consacré dans un journal au mariage d'une célèbre journaliste. Et dans cet article il y avait des détails donnés sur les éléments de la vie privée.

Dans la décision les juges ont considérés que ces informations étaient anodines, et donc quelle ne caractérisait pas une atteinte à la vie privée.

4) Titulaires du droit au respect de la vie privée

L'Art 9 du CC précise que chacun a le droit au respect de sa vie privée. On peut en déduire que ce droit au respect de la vie privée appartient à tout individu peu importe son âge, son rang, sa fortune, ses fonctions ou encore sa notoriété.

1ère chambre civile, 27 fev 2007, 06-10.393 « Mais attendu que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ».

Le contour des personnes publiques sont appréciés différemment des personnalités non publiques.

Deux remarques:

- Même les personnes connues/ publiques ont un droit au respect de la vie privée au même titre que l'individu lambda. La difficulté pour les personnes publiques réside dans la délimitation de ce qui relève de leur vie publique (et qui ne sera pas protégé) de ce qui relève de leur vie privée. Les personnes publiques intéressent la presse, que ce soit pour la presse à scandale ou pour la presse qui donne des informations. Pour les personnes connues il faut réussir à concilier d'un côté le droit

au respect de la vie privée et de l'autre coter la liberté de la presse avec la liberté d'information.

- Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie privée il faut remplir deux conditions :
 - La personne victime doit être vivante, le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée qui est seule titulaire de ce droit. Les droits de la personnalité sont intransmissibles, ils disparaissent avec leur titulaire. Le raisonnement est le même pour le droit à l'image.
 - Il faut être identifiable. Si il y a une publication faites sur un dirigeant mais qu'il n'est pas identifiable, ce dirigeant ne pourra invoquer le respect au droit de la vie privée.
- Cour de cassation, du 5 avril 2012, n°11-15.328.

B) Les comportements réprimés et les modalités de la protection

1) Quels sont les comportements considérés comme attentatoire a la vie privée

Il y a 3 formes d'atteinte a la vie privée :

- Recherche d'information ayant pour but de connaître la vie privée des personnes. Dans cette forme d'atteinte, le seul fait de chercher des informations sur la vie privée est considéré comme attentatoire à la vie privée (écouter les appels téléphoniques, pose de micros...).
- Divulgarion de renseignements qui concerne la vie privée d'une autre personne. Cette divulgation, peut faire suite a la première forme d'atteinte.
- La reproduction illicite de l'image d'une personne. C'est une atteinte au droit a l'image qui va être constituer par le fait de diffuser une photo, peinture ou dessin sur lequel la personne est identifiable sans son autorisation.

Il y a des nuances, pour les situations ou la personne se trouvait dans un lieu public. Il est possible de diffuser des images de lieu public, si la photo n'est pas directement cadrée sur une seule personne, ou cette diffusion peut-être justifier par l'information au publique. Dans cette catégorie d'atteinte il ne faut pas non plus détourner une image de son contexte. Ex: si je prend une photo d'un coureur cycliste pour la vendre a un fabricant de vélo. Pour en faire de la pub. C'est un détournement.

2) Comment s'opère les sanctions des atteintes a la vie privée

Il y a deux types de sanctions:

- Réparations en nature, Art 9 al 2 du CC. « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ». Il autorise les juges à prendre des mesures qui ont pour but d'empêcher de faire cesser l'atteinte à la vie privée.
- Sanctions pécuniaires, ces sanctions peuvent être prononcées soit devant un juge civil soit devant un juge pénal.

Au civil il suffira juste de prouver une atteinte a la vie privée. Alors qu'au pénal il faut porter plainte et se constituer parti civil.

Avant que l'Art 9 entre en vigueur il fallait prouver une faute, une préjudice et un lien de causalité.

Quand on évoque une réparation pécuniaire on peut demander des dommages et intérêts et le juge va fixer le montant de ces dommages et intérêts.

Le juge civil peut aussi prescrire des réparations en nature. Ex: le juge peut ordonner de faire publier une partie du jugement dans le même magazine.

Paragraphe 2 : L'honneur : la protection de la personne contre la diffamation et l'injure.

La diffamation et l'injure on en retrouve des définitions à l'**Art 29 du 29 juillet 1881, loi relative a la liberté de la presse.**

La diffamation peut se définir comme une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

Ex: je vais accuser mon employeur d'être un voleur.

L'injure c'est une expression outrageante ou méprisante mais qui ne contient l'imputation d'aucun fait précis.

L'injure et la diffamation sont deux comportements qui sont considérés comme des délits lorsque les propos sont prononcés publiquement, c'est à dire lorsque qu'il sont prononcés selon un des modes de communication selon la **loi de 1881** à l'**Art 23.**

Si l'injure et la diffamation ne sont pas prononcés publiquement ils sont qualifiés de contraventions.

Dans le cadre de l'injure, la difficulté et le la différentier de la critique. Car la critique est protégée par la **liberté d'expression.** Les poursuites pour injure sont parfois non sanctionnées quand les paroles sont dites dans le cadre d'un débat d'idées sur un sujet d'intérêt général. Il existe un droit de libre critique dans le cadre de ces débats.

Arrêt de la chambre criminel de la Cour de cassation du 23 novembre 2021, 21-80.681.

Un humoriste avait déclaré à la télé au sujet d'un candidat à l'élection présidentielle qu'il était « nié, nul et nocif ... ». Les juges ont considérés

« 11) Les juges concluent qu'il est admis un certain droit à l'irrespect et à l'insolence en matière politique, du fait précisément de la place de l'homme politique dans la société et de son engagement public, et que ce dernier sait qu'il s'expose à la critique et à la satire, particulièrement, comme c'est le cas en l'espèce, à l'occasion d'élections présidentielles même après le suffrage.

12) Ils en déduisent que la condamnation, même seulement civile, de M. [F], dont la profession est précisément de faire de l'humour noir et décalé, serait manifestement disproportionnée au regard des exigences de l'**article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.**

13) En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision...

14) En effet, les expressions poursuivies, pour outrageantes et grossières qu'elles soient pour la partie civile, critiquaient, sur un mode satirique et provocateur, les décisions d'un homme politique prises dans le contexte d'une élection politique, et ne dépassaient ainsi pas les limites admissibles de la liberté d'expression. »

Paragraphe 3 : La présomption d'innocence

La présomption d'innocence c'est le principe selon lequel chacun doit être considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.

Art 9 DDHC, il y a été consacré comme un droit sacré et inaliénable de l'Homme.

Art 6 paragraphe 2 CEDH « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

Art 9-1 CC « Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».

Ce droit implique qu'il est interdit de présenter une personne comme étant coupable d'une action temps quelle n'a pas été condamner.

Il y aura atteinte à la présomption d'innocence si l'auteur s'exprime de façon catégorique et non allusive ou hypothétique, s'il propage un préjuger ou une conviction sur la culpabilité de la personne, au lieu de se limiter à une simple description des faits.

Section 2 : Les limites intrinsèque de la protection de la vie privée : le consentement de la personne.

S'agissant du respect du droit au respect de la vie privée et au respect du droit a l'image. Ce sont des droits personnels qui protègent la personne mais cette personne est libre de renoncer à cette protection en révélant elle-même des faits de sa vie privée, voir en autorisant que ces éléments soient révélés. Certains personnalités moyennant finances donnent des informations sur leurs vies privées.

Lorsque la personne donne son consentement sur la divulgation d'informations personnels ou pour la reproduction de sa photo, dans cette hypothèse il n'y aura pas d'atteinte à la vie privée. Le consentement donner par la personne doit-être un boucle consentement. Il faut le consentement de noter les informations personnelles (consentement pour recueillir les informations personnelles) et la personne doit aussi donner le consentement de la divulgation à autrui.

Le fait d'autopsier quelqu'un a prendre une photo de soit ne donne pas l'autorisation de la diffusion de cette image.

Ce consentement de la personne peut-être exprès ou tacite, a condition s'il est tacite qu'il ne fasse pas l'objet d'un doute.

En principe le consentement de la personne ne doit pas être déduit de sa passivité ou d'une simple tolérance de sa part.

Consentement exprès : Accord d'une personne exprimé d'une manière apparente, telle qu'une signature ou une déclaration verbale non équivoque.

Consentement tacite : Accord d'une personne pouvant être déduit de son comportement ou de ses actes.

L'autorisation est tacite pour les personnes publiques s'agissant des photos prises dans un lieu public dans l'exercice de leurs activités.

Le consentement est un consentement spécial, c'est-à-dire que ce consentement vaut pour une atteinte précise dans une finalité déterminée. Donc la divulgation doit respecter les limites fixés par l'intéressé.

Ex: Si une actrice accepte de poser dénuder pour des cosmétiques, l'agence de publicité ne peut pas utiliser le photo pour une autre publicité.

Le consentement de la personne peut parfois comporter une contrepartie monétaire.

Section 3 : Les limites extrinsèques de la protection de l'intégrité morale : la confrontation avec la liberté d'expression.

Paragraphe 1: le droit au respect de la vie privée face à d'autres droits en concurrence.

Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental mais ça n'est pas un droit absolu. Pour s'en convaincre il faut lire l'Art 8 paragraphe 2 de la CEDH. « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Ça veut dire qu'il peut y avoir des ingérences dans le droit au respect de la vie privée si cette ingérence est prévue par la loi. Et quelle constitue une mesure nécessaire notamment à la protection des droits et libertés d'autrui.

Plusieurs droits concurrents peuvent rendre légitime une atteinte à la vie privée:

- **Liberté d'expression**, qui inclut le droit à l'information. C'est aussi une liberté constitutionnelle qui est protégée par l'Art 11 de la DDHC et également par l'Art 10 de la CEDH. Cette liberté d'expression a plusieurs composantes, c'est aussi un droit à l'information. C'est une liberté qui vise aussi bien la liberté de la presse d'informer le public, que le public de recevoir une information. Dans leurs rôles d'informations les médias peuvent être amenés à divulguer parfois des informations de la vie privée de certaines personnes, et parfois publier des photographies pour appuyer leurs propos qui relèvent d'un caractère public.

Si la personne concernée par les informations révélées, considère quelle est victime d'une atteinte à sa vie privée et quelle agit en justice. Le juge va devoir trancher un véritable conflit entre deux droits qui sont de valeur égale. À savoir le droit au respect de la vie privée d'un côté et de l'autre le droit d'expression du journaliste avec le droit à l'information du public. Le juge va alors utiliser une méthode qui s'appelle « la balance des intérêts » qui est la méthode utilisée et recommandée par la CEDH.

Ex: CEDH, 10 novembre 2015, *Couderc et Hachette Filipacchi contre France*, 40454/07.

Affaire qui concernait le prince de Monaco. Les faits se sont déroulés en 2015. C'est la magazine Paris Match qui avait publié l'interview d'une femme qui révélait avoir un enfant avec le prince Albert. Le prince a saisi la justice pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. Dans un premier temps les juges français lui ont donné raison dans une décision du 27 fév 2007 n°06-10.393 « Mais attendu que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée ; que l'arrêt relève d'une part que, à la date de la parution de l'article, l'existence et la filiation de l'enfant étaient inconnues du public, que d'autre part, la Constitution de la principauté exclut que, né hors mariage, il puisse accéder au trône, situation que, du reste, les conclusions de la société ne soutenaient ni être en débat dans les sociétés française ou monégasque, ni être étudiée par la publication litigieuse, et, enfin, que l'article comportait de nombreuses digressions sur les circonstances de la rencontre et de la liaison de Mme X... et du prince Albert, les réactions de celui-ci à l'annonce de la grossesse et son comportement ultérieur à l'égard de l'enfant ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu l'absence de tout fait d'actualité comme de tout débat d'intérêt général dont l'information légitime du public aurait justifié qu'il fût rendu compte au moment de la publication litigieuse ».

Sauf que la société d'édition a saisi la CEDH car elle considérée que la France avait porté atteinte à la liberté d'expression. La CEDH donna raison à la maison d'édition. La CEDH a condamné la France en considérant que la décision de 2007 portait atteinte à la liberté d'expression. Car les informations publiées par le magazine pouvait être considéré comme participant à un débat d'intérêt général et donc pouvait intéresser le public.

Pour la CEDH l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport au droit à la liberté d'expression.

Les juridictions françaises sont attentives à opérer correctement cette mise en balance quand elles sont saisis de litige dans lequel deux droits se confrontent. Quand les informations divulguées s'inscrivent dans un débat d'intérêt général ou dans un événement d'actualité la protection de la vie privée peut-être amoindrie face aux droits du public d'être informé. Les juges sont cependant attentifs, ils vont vérifier si la publication n'excède pas ce qui est nécessairement pour informer le public.

Arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, n°18-21.871. Dans ce reportage l'émission de télé avait révélé des informations personnelles du dirigeant.

- Droit à la sécurité.
- Droit à la preuve. Dans le cadre d'un procès, on peut être amené à produire des éléments pour vous défendre qui portent sur la vie privée d'une autre personne. En matière pénale la preuve est plus libre qu'en matière civile. Il existe un principe général qui est le principe de « loyauté de la preuve ». Ex: il y a eu en matière civile des décisions, dans lesquels les assureurs ont fait appel à un détective privé qui avait opéré des filatures. Dans ce contexte l'assuré va invoquer le droit à sa vie privée. Les juges vont donc utiliser la mise en balance.
- Protection de l'ordre public.

Paragraphe 2 : Le droit à la dignité : une limite infranchissable ?

A) Le droit à la dignité, une limite traditionnellement retenue.

La participation à un débat d'intérêt général, n'autorise pas les journalistes à ne pas respecter certains principes outre le respect de la vie privée. Il y a une limite qui a longtemps été considérée comme infranchissable et qui doit être aujourd'hui nuancée. C'est le droit à la dignité.

En jurisprudence on a plusieurs décisions dans lesquelles le principe de dignité est consacré comme étant un rempart ultime devant lequel la liberté d'expression doit céder. Les juges ont souvent rappelé que la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorise la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

3 arrêts :

— 1^{ère} chambre civile 20 décembre 2000, n°98-13.875

Le magazine Paris Match avait publié des photos du corps du préfet Erignac juste après son assassinat. Les juges ont estimé la publication illicite car elle portait atteinte à la dignité de la personne.

— 1^{ère} chambre civile 20 février 2001, n°98-23.471

Les photos concernaient l'attentat du RER B. ... La Cour a réaffirmé la décision du 20 décembre 2000.

— CEDH, 25 février 2016, requête n°4683/11

Jeune homme tué par le « gang des barbares », ils ont publié des photos où le jeune homme avait été torturé. Les juridictions françaises avaient exigé de supprimer certaines photos qui portaient atteinte à la dignité de cette personne. La CEDH a considéré que la décision des juridictions françaises était proportionnée vis-à-vis du respect de la dignité.

Le principe de dignité permet aussi de restreindre la liberté de réunion. Pour illustrer ce principe on peut évoquer les décisions qui ont été en rapport avec les interdictions préfectorales de spectacle de Dieudonné. Au nom du principe de dignité, certaines de ces représentations ont été interdites. En interdisant les spectacles on porte atteinte à la liberté de la réunion et à sa liberté d'expression. Cette restriction s'explique par le principe de dignité humaine.

B) Le droit à la dignité, une limite aujourd'hui discutée.

En 2019 la Cour de cassation a rendu une décision en assemblée plénière qui a semé le trouble concernant le fait de savoir si le principe de dignité constitue vraiment un rempart infranchissable face à la liberté d'expression. Arrêt 25 oct 2019. L'affaire concernait la diffusion d'une affiche parodique qui avait été publiée quelque jour plus tôt dans le journal Le Charlie Hebdo. Intitulée Mme Lepen une

candidate qui vous ressemble.

Arrêt assemblée plénière = arrêt de principe = arrêt très important pour le droit français.

Mme Lepen disait qu'il s'agissait d'une injure publique. Le débat était aussi de savoir si la publication portait atteinte à sa dignité. Les juges ont considérés que l'animateur devait être relaxé. Car ce dernier n'avait pas dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression. Les juges ont basé leur décision sur le fait que le journal était satirique et que l'on était dans une période électorale. Mais les juges ont mis en évidence dans cette décision une formule étonnante énonçant que « la dignité ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression ». Cela signifie que la Cour semble dire que la dignité n'est pas une exemption autonome à la liberté d'expression. Elle adopte une opposition protectrice vis-à-vis de la liberté d'expression.

Les juges du fond sont venus réaffirmer cette formule dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 16 juin 2021. Cette affaire concernait une exposition qui était intitulée « l'infamille » dans laquelle un artiste exposait des lettres choquantes, des lettres écrites par des parents fictifs pour leurs enfants. Dans les lettres le contenu était violent. « Les enfants nous allons vous enfermer vous êtes notre chair et nos esclaves... ». Une association a assigné l'organisateur de l'exposition en invoquant une atteinte portée à la dignité humaine. L'affaire est montée jusqu'à la Cour de cassation. L'arrêt de 2021 est l'arrêt de la Cour d'Appel de renvoi. Cette Cour fait une référence à l'arrêt de 2019 et rappelle que « l'atteinte à la dignité ne peut constituer un fondement autonome de restriction à la liberté d'expression ».

Le principe de dignité constitue une limite à la liberté d'expression seulement quand la liberté d'expression est confrontée à d'autres intérêts en présence (comme la liberté) mais pas quand il est invoqué seul. Le principe de dignité devrait seulement être pris en compte dans le cadre du contrôle de proportionnalité dans la balance des intérêts.

Dans cette dernière affaire l'association invoquait qu'une atteinte à la dignité qui résultait de la liberté d'expression. Mais pas une atteinte à d'autres droits et c'est ce qui a probablement conduit les juges à considérer que la dignité n'était pas une limite à la liberté d'expression.

Thème 4 : protection de l'intégrité physique des personnes

Paragraphe 1 : La protection de la vie humaine.

A) Le droit à la vie

Le droit à la vie est affirmé en droit interne mais aussi dans les textes internationaux de protection des droits de l'homme.

Droit interne

- L'Art 66-1 constitution possède un principe d'interdiction de la peine de mort.
- Dans le CP on sanctionne les atteintes à la vie d'autrui.
- Art 16 CC, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie »

Droit supra-national de très nombreux textes protègent le droit à la vie.

- Art 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ».
- Art 6-1 du pacte des Nations-unies relatif aux droits civil et politiques (1966) « Il ne peut être admis

aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré ».

- Art 2 §1 de la charte de l'UE « Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ».
- Art 2 de la CEDH « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».

Il y a quand même des limites, des tempéraments. Ex: la légitime défense, qui est autorisé par le CP. On peut penser aux atteintes portées à l'embryon et au fœtus.

B) Existe-t-il un droit à la mort ?

Il faut s'interroger sur la question de la fin de vie, et plus particulièrement sur la question de l'euthanasie.

L'euthanasie se définit comme un acte provoquant le DC d'une personne souffrant d'une maladie incurable dans l'optique d'abrèger ses souffrances.

En droit français on n'autorise pas l'euthanasie n'y le suicide assisté. Le droit français a fait le choix d'accompagner le plus dignement possible les personnes en fin de vie mais non de leur administrer la mort.

Notre système actuel est le fruit d'une évolution législative.

Qui a commencé par la loi du 4 mars 2002 qui a prévu que les médecins doivent mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Au besoin/ en ayant recours à des soins palliatifs.

On a eu une seconde loi du 22 avril 2005 « loi Léonetti » à consacrer un droit à mourir dans la dignité par l'arrêt des soins et la mise en place de soins palliatifs. Depuis cette loi de 2005, les personnes qui souffrent d'une maladie terminale. Pour laquelle elle sont en phase avancée ou terminale de la maladie ont le droit de demander l'arrêt des soins. Les soignants et les médecins ont de façon tacite, le droit de laisser mourir le patient. Cette loi est venue également recommandé aux médecins d'éviter l'obstination déraisonnable/ l'acharnement thérapeutique. Cette dernière permet par les soins palliatifs d'administrer des traitements dit à double effets. Ils ont pour effet de soulager les douleurs, et on sait que plus on augmente les doses plus on diminue l'espérance de vie.

On a eu une loi du 2 février 2016, « loi Claeys-Léonetti » c'est une continuité de la loi de 2005. Mais elle vient renforcer la place de la volonté des malades en fin de vie, l'innovation majeure c'est d'avoir consacré un droit à la sédation profonde et continue qui est énoncée à l'Art L1110-5-2 CSP.

L'Art L1110-5-2 CSP: Toute personne qui remplit les conditions posés dans cet article. C'est-à-dire les personnes atteinte d'une infection grave et incurable avance un pronostic vital engage a court terme, ou les personnes qui, atteinte de cette même infection, demandent l'arrêt des traitements et peuvent demander à être placés en sédation profonde et continue jusqu'à leur DC. C'est une sorte de coma artificiel. Si le patient ne peut pas exprimer sa volonté et que les équipes médicales décident d'arrêter le traitement de maintien en vie. Les médecins doivent appliquer une sédation profonde et continue.

Art L1110-5-2 CSP : « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie »

Ces questions autour de la fin de vie font l'objet de réflexions permanentes. Il y a très fréquemment de nouvelles propositions de lois pour faire évoluer le cadre juridique. Dernièrement le CCNE (Comité

Consultatif Nationale d'Éthique) à déposer un avis en septembre 2022 (l'avis 139). Il a mis en évidence que notre cadre juridique était assez satisfaisant quand une personne à un pronostic vital est engagé à court terme mais le cadre n'est pas assez satisfaisant pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Il y'a une convention citoyenne qui ouvre le débat sur cette question cette convention devrait commencer en décembre 2022 qui devrait donner des conclusions en mars 2023.

Affaire Vincent Lambert: l'histoire d'un jeune homme qui est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de moto en 2008. Et il est dans un état végétatif, il n'avait comme soin qu'une alimentation et une hydratation artificielle. Son épouse était favorable à un arrêt des soins (elle était sa personne de confiance) et ses parents souhaitent continuer les traitements. Cette affaire a duré 11 ans. Onze années durant lesquelles les médecins devaient se poser la question de savoir si c'était déraisonnable de continuer les soins. Toutes juridictions ont été saisies. Finalement les traitements se sont arrêtés le 2 juillet 2019. Et Vincent Lambert est DCD le 11 juillet 2019.

Paragraphe 2 : La protection du corps humain.

La protection du corps humain résulte des lois de bioéthiques de 1994 qui sont venues inscrire plusieurs articles relatifs au corps humain que l'on retrouve à l'Art 16-1 CC « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »

A) L'inviolabilité du corps humain

L'inviolabilité du corps humain signifie que le corps ne peut faire l'objet d'aucune atteinte en principe ni par la personne elle-même ni par des tiers.

Le principe d'inviolabilité vise surtout à encadrer les atteintes qui pourraient être portées au corps humain d'une personne par un tiers. Cette protection est affirmée à l'Art 16-3 CC Al 1 « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui » Al 2 « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

Pose un principe de respect de l'intégrité du corps humain.

Le corps humain est inviolable il doit faire l'objet d'une protection. Les atteintes au corps humains sont accordées dans deux conditions.

1) Les conditions pour porter atteinte au corps humain

A) Une finalité spécifique

L'atteinte doit répondre à l'une des finalités énoncées par l'Art 16-3. À savoir la nécessité médicale pour la personne soit l'intérêt thérapeutique d'autrui.

- **Nécessité médicale pour la personne:** les actes médicaux portent nécessairement atteinte au corps humain. Pour pouvoir effectuer ces actes médicaux doivent répondre à une nécessité médicale. Cette nécessité est appréciée de façon large. Car cela inclut les actes indispensables à la santé de la personne que des actes qui sont jugés utiles.

Ce cadre juridique impose que les médecins ne peuvent pas en principe réaliser des actes médicaux qui ne sont pas commandés par une nécessité médicale.

- **Intérêt thérapeutique d'autrui**: un acte médical peut aussi être réalisé sur le corps d'une personne s'il répond à une finalité liée à l'intérêt thérapeutique procurer à un tiers. C'est cette finalité qui permet de procéder à des prélèvements d'organes sur les personnes vivantes pour les transplanter sur une autre personne.

Pour les **prélèvements et les dons d'organes** qui concernent des personnes vivantes. Il faut le **consentement du donneur** mais il faut en outre **prouver un intérêt thérapeutique direct pour le receveur**. Le don d'organe du vivant est très encadré car il est considéré par les textes comme un acte de solidarité qui doit intervenir entre proches. **Art L1231-1 CSP hiérarchise qui peut donner**. En principe on ne peut pas donner un organe à un inconnu.

B) Il faut un consentement de la personne concernée

En principe le corps humain étant inviolable toute personne doit donner son consentement avant tout acte médical sans quoi cela constituerait une atteinte à son intégrité physique. Cette exigence du consentement a pour but de protéger la personne contre les tiers. Ce consentement à l'acte médical doit être éclairé (consentement donné après avoir reçu une information appropriée).

Il y a des tempéraments quand la personne n'est pas en capacité de consentir, ce qui est le cas d'une personne inconsciente dont on **va présumer le consentement au regard de la nécessité de l'intervention ou du traitement**. Cela signifie que toute personne est libre de refuser des soins. **L1111-4 CSP**. Le médecin qui respecte la volonté du patient ne saurait être poursuivi. À l'inverse le médecin qui interviendrait sans le consentement de la personne outre le consentement qui outrepasserait le consentement de la personne **pourrait être poursuivi**. Il y a une nuance quand la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté et que l'acte médical est nécessaire à sa survie.

Ex: Les personnes qui sont témoins de Gêova qui refusent toutes les transfusions sanguines. Décision du CE qui a statué en référé le 20 mai 2022 ordonnance n°463-713. Il s'agissait d'une personne victime d'un accident sur la voie publique et qui portait sur elle un document indiquant qu'elle refusait toutes transfusions sanguines peu importe les circonstances. La personne avait désigné une personne de confiance qui avait confirmé la décision de refus de la transfusion sanguine. Cependant les médecins procèdent aux transfusions sanguines. Donc les proches saisissent le juge administratif pour qu'il ordonne aux équipes médicales de respecter les directives du patient et qu'ils cessent les transfusions. La juridiction administrative n'a pas fait droit à leur demande. Car les juges ont considérés que les médecins pouvaient s'écarter des instructions du patient au regard du fait que ces actes médicaux (transfusions) étaient indispensables à sa survie et proportionnés à son état alors qu'il était hors d'état de manifester sa volonté.

C'est une décision qui vient réduire la valeur des directives anticipées.

2) Les tempéraments au principe d'inviolabilité

Plusieurs tempéraments au principe d'inviolabilité:

- **Ordre public**. Des motifs d'ordre public peuvent justifier de tempérer le principe d'inviolabilité du corps humain. **Les campagnes de vaccination obligatoires, constituent une atteinte de l'intégrité physique de la personne mais elles sont possibles car elles répondent à un objectif de santé publique/ objectif d'intérêt général. Qui va primer sur l'intégrité physique individuel de chacun.**
- **La protection d'autres libertés fondamentales**. Le principe de protection du corps humain devrait en principe protéger le corps également contre la volonté de la personne elle-même. Pour autant le droit au respect de la vie privée et l'autonomie individuelle prennent parfois le dessus et on constate qu'il existe un droit de chacun à l'auto-détermination. Que l'on doit mettre en parallèle avec le principe d'indisponibilité du corps humain.

— **Droit à l'auto-détermination**: La CEDH protège un droit à l'autonomie personnelle. **La décision de la CEDH du 17 février 2005 K.A et A.D contre Belgique**. Qui concernait deux belges qui s'étaient adonnés à des pratiques sadomasochistes. Et qui avaient été condamnés pénalement en Belgique. Alors qu'au départ les personnes étaient consentantes. Le mari a été condamné et il a saisi la CEDH. La CEDH énonce que « le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre de l'individu » la cour ajoute « il fait des raisons particulièrement graves pour que soit justifiées, aux fins de l'Art 8 § 2 CEDH » (de la convention). Une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité. Selon la Cour, le consentement des personnes peut suffire à justifier des atteintes portées au corps mais dans cette affaire (dans ce cas d'espèce) la Cour a considéré que les autorités belges avaient pu légitimement intervenir en énonçant des condamnations.

On peut se questionner sur la légitimité/ possibilité de se faire tatouer. Ces actes sont permis car la personne est autorisée au nom du droit au respect de la vie privée et de l'autonomie individuelle. On peut aussi évoquer la question de la circoncision pour des motifs religieux. La aussi il y a une tolérance qui est fondée sur la liberté de religion, sur le libre exercice des cultes qui va permettre l'atteinte portée au corps humain.

C'est un sujet qui n'est pas jugé de la même façon partout. Allemagne en 2012 un tribunal avait jugé que la circoncision qui avait été faite dans un but non médical pouvait être sanctionnée pénalement.

B) La non patrimonialité du corps humain

1) Principe

Le principe de non-patrimonialité du corps humain a été inscrit dans le CC par **une des lois de bioéthiques de 1994**. C'est un principe d'ordre public que l'on retrouve énoncé à l'Art 16-1 Al 3 CC « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ».

Ce principe est précisé aux **Arts 16-5 et 16-6 CC**.

Art 16-5 CC « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles »

Art 16-6 CC « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ».

Ces articles visent à lutter contre les tentatives de réifications du corps humain (des tentatives qui viseraient à traiter le corps humain comme une chose).

Ces articles interdisent que soit constitué sur le corps un droit susceptible d'être monnayé.

En réalité à part pour les conventions de GPA, les conventions à titres gratuits sur le corps humain sont licites pour permettre des interventions jugées utiles dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'autrui. **Ex: dons : organes, gamètes.**

Qui sont licites tout en respectant le principe de non-patrimonialité.

2) Corollaires de ce principe

Le principe de non-patrimonialité explique l'anonymat et le principe de gratuité qui commande tout don d'un élément du corps humain. L'anonymat implique que l'identité du donneur reste secrète pour le receveur et inversement. **Cependant le don de gamète depuis la loi du 2 août 2021 n'est plus anonyme.**

3) Exceptions

Certains produits du corps humain peuvent faire l'objet de conventions onéreuses. C'est le cas du lait

maternelle, ongles, cheveux et dents .

Art L1211-8 CSP

R1211-49 CSP

Thème 5: la protection des majeurs

Pendant longtemps on a intitulé cette partie du cours le droit des incapacités, le droit des incapables.

Aujourd'hui on préfère l'expression droit des majeurs protégés ou vulnérables.

On utilise l'expression incapable pour désigner les majeurs vulnérables par référence à la notion de capacité juridique. Aujourd'hui on préfère l'expression droit des majeurs protégés ou vulnérables mais il n'en demeure pas moins que la personne protégée est frappée d'une incapacité juridique.

Paragraphe 1: Définition capacité juridique

La capacité juridique est intimement liée à la notion de PJ. La capacité juridique (CJ) c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit et d'obligations. C'est l'aptitude à acquérir des droits et à les exercer. Cependant parmi les personnes physiques qui ont la PJ, certaines peuvent être privées de tout ou partie de cette aptitude. C'est-à-dire que l'on va leur enlever leur capacité juridique en raison de leur vulnérabilité.

Cette vulnérabilité de la personne a donc des effets sur sa situation juridique.

L'Art 1145 CC précise « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ».

Pour comprendre le droit des incapacités il faut que nous arrivions à faire une distinction première entre la capacité de jouissance et capacité d'exercice.

La capacité juridique au sens large comporte deux aspects:

- Capacité de jouissance: l'aptitude à être titulaire d'un droit.
- Capacité d'exercice : l'aptitude à exercer le droit dont-on est titulaire.

A) La capacité de jouissance

La capacité de jouissance, c'est l'aptitude à être sujet de droit, à être titulaire de ces droits. À l'inverse l'incapacité de jouissance c'est l'incapacité à être titulaire de droit. C'est une mesure grave car c'est lié à la PJ.

C'est ce qui explique qu'il n'y a jamais d'incapacité de jouissance générale, sinon cela reviendrait à nier la PJ de l'individu. Cette incapacité de jouissance ne sont jamais générales elles sont toujours circonscrites à certains droits. Elle prive la personne qui en est frappée de certains droits. Elles sont très rares.

Art 904 CC « le mineur de moins de 16 ans ne peut pas faire de testament, ni disposer (il ne peut pas faire de donation). »

D'autres incapacités pour éviter des détournements d'héritages:

Art 909 CC, interdit aux médecins de recevoir un bien en vertu d'une donation ou d'un testament consenti par un patient dont-il a traité la maladie qui a conduit à son décès. Le patient est dans une situation de vulnérabilité.

Art L-116-4 du code de l'action sociale et des familles. Interdit aux personnels des maisons de retraites ou des établissements psychiatriques de se porter acquéreur des biens vendus par les pensionnaires. Le but étant de protéger le patrimoine de la personne vulnérable.

Ces deux dispositions portent atteintes au droit de propriété, limite aussi la liberté contractuelle. Art 909 CC, limite le droit de propriété. Art L-116-4 CC porte atteinte à la liberté contractuelle.

Ils y a eu des décisions du CConst pour savoir si ces dispositions sont conformes ou pas à la C58.

Décision du 29 juillet 2022 du CConst, concernait l'Art 909 CC. Dans cette décision le CConst a déclaré conforme à la constitution l'Art 909 Al 1 CC, il a considéré que l'atteinte au droit de propriété est justifiée/ proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation.

Décision du 12 mars 2021, CConst statue sur l'Art L-116-4 CC. Le CConst a partiellement censuré cet article parce qu'il interdisait aux personnes dépendantes de gratifier les personnes qui leur apportaient des services à domicile. Cette décision a considéré que cette interdiction portait une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection qui était poursuivi.

En dehors de ces hypothèses il faut reconnaître que la capacité de jouissance est générale et absolue puisqu'elle est intimement liée à la PJ de l'individu.

B) La capacité d'exercice

La capacité d'exercice est la faculté pour la personne titulaire de droits de pouvoir les exercer librement et par elle-même.

À contrario l'incapacité d'exercice c'est une inaptitude de la personne à faire valoir par elle-même dans la vie juridique les droits dont elle est titulaire. Les droits dont elle jouit grâce à sa capacité de jouissance. Cette incapacité d'exercice est courante. Il est fréquent que l'on ait la jouissance d'un droit sans avoir la capacité juridique de l'exercer.

Dans les hypothèses d'incapacité d'exercice, l'acte que l'individu ne peut pas faire seul pourra être accompli pour son compte par son représentant.

Il y a deux motifs d'incapacité d'exercices:

- L'incapacité liée à l'âge.

Le mineur de moins de 18 ans est en principe incapable d'exercer ses droits. Il y a un principe d'incapacité d'exercice de plein droit du mineur (tous les mineurs). C'est une incapacité considérée comme naturelle. Car le mineur semble de prime abord inapte à exercer les droits dont-il est titulaire. On admet que le mineur peut accomplir certains actes juridiques, soit parce qu'ils sont anodins, soit parce qu'ils sont très personnels (possibilité pour une femme mineure de faire une IVG).

Cette tolérance s'accroît au fur et à mesure que le mineur s'avance vers la majorité. Ex: un mineur peut signer un contrat de travail.

- L'incapacité qui est liée à une altération des facultés mentales.

En principe dès la majorité on obtient la pleine capacité d'exercice. Art 414 CC. « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ».

À partir de 18 ans la capacité d'exercice constitue le principe pour le majeur et l'incapacité constitue l'exception.

Seule la constatation judiciaire des facultés mentales ou physiques atteignant le discernement permet de déroger au principe général de la capacité d'exercice de la personne physique majeure. La personne majeure qui fera l'objet d'une telle altération d'une faculté mentale, pourra faire l'objet d'une mesure de protection.

Les Arts 1145 et 1146 CC. Illustrent bien cette idée.

Art 1145 CC: toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

Art 1146 CC: sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi: Mineurs non émancipés; Majeurs protégés au sens de l'Art 425 CC.

Pendant longtemps il y avait une incapacité liée au sexe liée à la femme mariée, abrogée par les lois de

1938 et 1942.

Paragraphe 2 : Les sources principales du droit des personnes vulnérables

La spécificité du droit des personnes vulnérables, c'est qu'il n'y a pas de partie spécifique dans le CC qui soit consacré à cette thématique. La protection des personnes vulnérables passe par plusieurs institutions qui sont l'autorité parentale (Titre IX), mineurs (Titre X), majeurs (Titre XI) du livre premier. Mais on trouve aussi des textes relatifs à la capacité dans la partie relative aux contrats dans le CC. Ex Art 1145 CC: Art propre aux contrats.

Le droit des majeurs vulnérables a aussi des liens étroits avec le droit de la famille parce que les organes de protection de la personne vulnérable sont toujours recherchés en priorité dans la famille.

Sous-thème 1 : la protection ponctuelle du majeur indépendamment de l'ouverture d'une mesure juridique de protection

La protection d'une personne majeure peut-être occasionnel/ ponctuel sans que soit ouvert une mesure de protection juridique.

Cette protection va passer par l'un des deux mécanismes:

- Biais d'une habilitation judiciaire
- Soit une action passe en nullité sous l'emprise d'un trouble mental

Section 1 : La représentation dans le cadre du couple marié (l'habilitation judiciaire)

Il y a des mécanismes qui permettent lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté, de la faire représenter par son époux (si elle est marié) du moins pour les actes qui nécessitent leurs consentements conjoints. Art 217 CC qui prévoit cette hypothèse et qui va permettre à l'époux dont le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté. Il va demander au juge l'autorisation d'effectuer seul un acte juridique pour lequel il devrait en principe avoir le consentement de son conjoint.

Les causes:

- L'infirmité
- Éloignement géographique
- Absence prolongée
- Cas où le refus du conjoint est contraire à l'intérêt de la famille

Il y a un autre mécanisme, c'est la représentation judiciaire présent à l'Art 219 CC « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habilité par la justice à le représenter. De manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixée par le juge ». Permet à l'époux représentant de représenter l'époux incapable de s'exprimer même pour des actes qui lui appartiennent exclusivement. Même pour des actes juridiques pour lesquels l'époux représentant n'a aucun pouvoir à l'origine. Ex: sur des biens personnels de son conjoint.

Section 2 : L'action en nullité d'un acte passé sous l'emprise d'un trouble mental

Un acte = un acte juridique (dans cette section)

Cette seconde protection ponctuelle est prévue à l'Art 414-1 CC qui dispose « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».

Toute personne qui aurait réalisé un acte juridique alors qu'elle était sous l'emprise d'un trouble mental aura la possibilité d'en demander la nullité.

Il y a deux conditions à cette action, pour obtenir la nullité de cet acte il faut prouver:

- Qu'un trouble mental affecté la personne auteur de l'acte.
- Que ce trouble mental s'est produit au moment même où la personne a réalisé l'acte.

Le trouble mental n'est pas défini par le législateur, mais il faut faire une distinction entre le trouble mental et la maladie mentale.

Le trouble mental est plus général que la maladie mentale. Et la jurisprudence retient une conception large du trouble mental. Du moment que le trouble invoqué permet d'exclure l'existence d'un consentement sain/ entier par la personne. Autrement dit le trouble mental c'est l'altération des facultés mentales qui atteint la capacité de réflexion ou de décisions de la personne et qui justifie donc l'annulation de l'acte juridique qu'elle a passé sous l'emprise de ce trouble mental.

Les juges ne distinguent pas en fonction de la durée. Les juges ne distinguent pas en fonction de leurs étendus. Il suffit de prouver qu'il y a eu un trouble mental qui a atteint le discernement au moment de l'acte. C'est une appréciation des juges du fond en fonction des éléments qui leur sont soumis.

Ex: personne atteinte d'Alzheimer, ...

La difficulté pour ces actions, c'est sur le terrain probatoire quelle est la plus grande (terrain de la preuve) Pour simplifier cette preuve la jurisprudence a admis qu'on puisse prouver l'insanité d'esprit (trouble mental) dans la période antérieure à l'acte litigieux et dans la période postérieure.

Sous-thème 2 : La protection durable des majeurs vulnérables

Les mécanismes qui permettent de mettre en place une protection plus durable des majeurs dit vulnérables, qui sont dans une situation telle, qu'ils ne peuvent plus pourvoir à leurs intérêts par eux-mêmes. Ils ne peuvent plus exercer pleinement leurs droits.

Section 1 : Éléments d'introduction et distinction entre la protection de la personne elle-même et la protection de son patrimoine

Les majeurs qui sont atteints dans leurs facultés intellectuelles/ mentales qui font l'objet d'une vulnérabilité, peuvent bénéficier de mesures de protections juridiques qui vont amoindrir leur capacité juridique d'exercice voir la faire disparaître.

Ces mesures de protection juridique, ce sont des mesures qui sont très strictement encadrées par des principes fondamentaux qui sont:

- Respect de la liberté individuelle
- Respect des droits fondamentaux de la personne
- Respect de sa dignité

Ces principes commandent de toujours garder en tête que l'incapacité constitue une exception et il faut toujours essayer de tenir compte de la volonté de la personne lorsque cela est possible, même pour les majeurs les plus atteints dans leurs facultés.

Les mesures de protections qui existent sont au nombre de 5:

- Mandat de protection futur : Cette mesure a pour objet d'anticiper une éventuelle perte de capacité physique ou mentale, qui se traduirait par une mise sous tutelle ou curatelle.
- L'habilitation familiale : Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n'est pas en

mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.

- **La sauvegarde de justice** mesure de protection de courte durée. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignante. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une médicale et une judiciaire (prise par le juge).
- **La curatelle** : La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur et son patrimoine. Elle lui permet d'être conseillé et/ou d'être accompagné pour les actes importants. Et ce, même si elle reste autonome pour accomplir des actes simples
- **La tutelle** : La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur : Personne désignée pour exercer une mesure de protection, la représente dans les actes de la vie courante. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas

Ce sont des mesures qui vont être mises en place lorsque l'on va constater qu'une personne majeure fait l'objet d'une altération de ses facultés mentales et qu'elle n'est donc plus en mesure d'effectuer certains actes seul, ou tout simplement de défendre ses intérêts. Le droit va donc la protéger et selon son autonomie, selon sa faculté de discernement la mesure sera plus ou moins contraignante. Et lui laissera plus ou moins d'autonomie pour agir par elle-même.

Il y a une personnalisation de la mesure possible (le juge peut personnaliser les actes qui ont besoin d'une supervision).

Ces mesures ont pour but de protéger à la fois la personne elle-même. Ex: décisions médicales. Mais aussi de protéger son patrimoine. Ex: pour la décision de vendre ou donner un bien.

Ces mesures de protections présentent une dualité. C'est la Loi du 5 mars 2007, loi de réforme de la protection des majeurs. Elle a posé le principe que la protection ne concerne pas seulement les biens, elle concerne aussi la personne. Cette dualité est retrouvée aux Arts 415 et 425 Al 2 CC.

Art 415 CC « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ».

Art 425 Al 2 CC « S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».

Les principes généraux qui gouvernent ces deux aspects de la protection sont différents.

Paragraphe 1 : La protection du patrimoine: une protection pour la conclusion d'actes engageant le patrimoine du majeur

Selon les personnes leur degré d'altération mentale est différents. Le degré d'atteinte des facultés mentales détermine le choix de la mesure de protection.

Pour la protection du patrimoine.

A) Différentes modalités d'accompagnement : assistance, représentation ou l'autorisation

Selon la nature de l'acte à accomplir et selon les facultés personnelles du majeur qui fait l'objet d'une protection, les techniques de protections vont être différentes.

Il y en a 3 sortes:

- **La représentation**

Les incapacités les plus graves on comme palliatif la représentation. Dans ces hypothèses le majeur

qui est incapable juridiquement ne figure pas en personne sur la scène juridique il n'émet pas la volonté à l'origine de l'acte et elle ne le signe pas. C'est comme si sa personnalité passe au second plan car la loi a permis que soit désigné un représentant qui va agir en son nom et pour son compte. C'est la situation classique du mineur et c'est aussi la situation du majeur en tutelle qui est représenté par un tuteur.

- **L'assistance**

Procéder plus souple qui permet à l'incapable d'agir lui-même, mais à condition d'être assisté. C'est la mesure utilisée pour la mesure de curatelle. Le majeur protégé reste à la tête de ses affaires et la loi va simplement enjoindre qu'il est à ses côtés une personne avisée qui agira avec elle pour compléter sa capacité imparfaite.

La volonté personnelle du majeur assisté est nécessaire à l'acte juridique que le majeur va signer.

- **L'autorisation**

Dans l'autorisation on se rapproche de l'assistance, mais ce dernier implique un accord préalable d'une autorité (ex: juge des tutelles —> juge contentieux ...) qui va permettre au majeur protégé d'agir seul ensuite.

Le système de l'autorisation peut se superposer à celui de la représentation ou de l'assistance. Car pour certains actes le représentant légal va devoir demander une autorisation du juge. Ex: actes de dispositions. Pour les actes de dispositions les tuteurs doivent demander l'accord du juge pour effectuer la vente.

B) Une répartition des pouvoirs en fonction de la nature des actes concernés

La notion de pouvoir est une notion différente de la capacité. Le pouvoir s'est l'aptitude à exercer les droits d'autrui, c'est l'aptitude à agir pour le compte et au nom d'autrui. Lorsqu'un majeur est protégé par une mesure de tutelle, il est représenté. Le tuteur va avoir des pouvoirs d'agir ou non pour la personne qu'il représente.

Les pouvoirs du représentant vont dépendre du type d'acte qui est en cause.

Il va falloir pour chaque acte se poser la question de savoir, est-ce qu'il s'agit d'un acte conservatoire (catégorie la moins grave), s'agit-il d'un acte d'administration (un peu plus grave) ou s'agit-il d'un acte de disposition (très grave).

Il va falloir qualifier l'acte, pour pouvoir déterminer ce que le majeur peut encore faire seul, mais aussi pour déterminer ce que son tuteur peut faire seul. La loi fait une distinction entre ces trois actes, elle utilise cette trilogie d'actes qui constitue un guide des pouvoirs, grâce à ce dernier on va pouvoir délimiter les pouvoirs respectifs du majeur protégé, de son assistant, de son représentant ou du juge.

Il faut définir et qualifier les actes. Depuis la réforme du 5 mars 2007, pour éviter les discussions sans fin sur la nature de l'acte en cause, une classification a été proposée par décret. Décret du 22 décembre 2008: donne des définitions générales de ces trois actes. Ce décret établit des listes.

Les actes conservatoires: ce sont les actes qu'il permettent de sauvegarder le patrimoine de la personne, sans compromettre aucune prérogative du propriétaire. Ce sont les actes les moins graves.

Ex: payer une facture

On considère que les actes conservatoires peuvent toujours être effectués par le majeur protégé.

Les actes d'administrations: ce sont des actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénué de risques anormaux. Ce sont les actes nécessaires à la gestion courante d'un bien qui permettent de le conserver, de la faire fructifier sans compromettre sa valeur.

Ex: conclure un bail sur un appartement dont-on est propriétaire, souscrire à un contrat d'assurance.

Les actes engageant plus le patrimoine de la personne, il faut donc regarder le jugement pour savoir

lesquels sont admis et pour qui.

Les actes de dispositions: ce sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée. Ce sont les actes les plus graves.

Ex: vente d'un immeuble

Pour ces actes il faut obligatoirement la présence du représentant, et il faut demander une autorisation préalable au juge.

